

西方憲政主義進入臺灣社會的 歷史過程及省思*

王泰升**

目次

壹、前言	一、以「訓政前置主義」箝制自由民主憲政
一、問題意識	二、非常體制下的憲政主義實踐：以雷震案為例
二、研究對象	三、重行集結的行動者
貳、日本殖民統治下的憲政主義初體驗	肆、政黨輪替下的憲政主義新體驗
一、伴隨憲法爭議而來的憲政主義概念	一、自由民主憲政的實現及人民憲政觀的轉變
二、西方憲政主義的在地實踐：以臺灣議會請願運動為例	二、國家真實與法制上宣稱矛盾以及相異的國族認同
三、缺席的行動者：高山族原住民	三、觀念分歧的行動者
四、整個日治時期程度有限的初體驗	四、認同自由民主憲政的國家認同
參、國民黨一黨專制下的憲政主義再體驗	伍、結論：歷史思維下的未來展望

* 投稿日：2012年3月22日；接受刊登日：2012年12月18日。〔責任校對：陳榕〕。
感謝臺大法律學院王志弘博士生，為本文蒐集相關文獻並為初步整理。初稿曾發表於中央研究院法律學研究所主辦，「第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會」（臺北，2010年12月9-10日），感謝評論人薛化元教授及其他與會者惠賜指教，其後為納入臺灣最新的發展情況及研究成果，已做相當程度的修改。同時也感謝兩位匿名審查人的指正。

** 國立臺灣大學法律學院特聘教授、中央研究院臺灣史研究所暨法律學研究所合聘研究員。
穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/10502041.pdf>。



摘 要

臺灣社會於19世紀末，因被日本統治而首度接觸西方憲政主義。當時日本本身即僅具立憲主義的外觀，臺灣人對於國家法能有多少立憲主義成分既不知也無從改變。然而，1920年代一些臺灣人知識菁英已展現出對於西方憲政主義的理解及加以善用的企圖，臺灣人也因此於1935年後初次體驗民主選舉，但高山族原住民族則幾乎是被排除在外。

戰後的由外省政治菁英組成的國民黨政權，帶來了具有西方憲政主義憲法條文、但以動員戡亂及戒嚴凍結其效力的中華民國憲政體制，實質上延續其在中國訓政時期悖離立憲主義的法律生活方式。本省人族群對此無力反抗，少數來自中國的自由主義者在欠缺群眾支持下亦難以對抗。於1970年代和1980年代，某些接受戰後西方憲政主義思潮的新生代法學者，以及以本省人族群為主之「黨外」及民進黨政治菁英，重新集結以對抗之，而國民黨除繼續培育外省政治菁英，更吸納某些本省人政治菁英以應民主選舉之需。西方立憲主義社會基盤之一的存在兩股以上政治勢力，已悄然出現其雛形，進而使得強人蔣經國1988年過世後，李登輝於1990年代將臺灣社會導向自由民主化，並在2000年經由首次政黨輪替實現了自由民主憲政。

過去只靠不斷的選舉來堆砌自由民主憲政的外觀，卻一直未培育出在對抗之後必要的相互協商、形成共識的憲政文化。分歧的國族認同，加上現實的政治和經濟利益的爭奪，使兩股社會力／政治力僵持不下，導致國家發展停滯。國民黨於2008年不僅重新執政，且獲得壓倒性的優勢，但臺灣自由民主之途卻更為坎坷。於今，臺灣人民應補修過去因急於「使用」民主選舉，而來不及省思的西方憲政主義的法政基本理念，讓臺灣人民的「國家認同」，就等於是對自由民主憲政生活方式的認同。

關鍵詞：立憲主義、憲政主義、民主、憲法、人權、國族主義、國族認同。

Reflections on the Introduction of Western Constitutionalism into Taiwan's Society

*Tay-Sheng Wang**

Abstract

People in Taiwan encountered Western constitutionalism for the first time due to their being ruled by Japan in the late 19th century. Japan itself, however, had carried out constitutionalism in form only. The ruled Taiwanese were not acquainted with constitutionalism and thus cannot challenge the extent to which constitutionalism had been adopted by the positive law in colonial Taiwan. Nevertheless, Some Taiwanese elites had shown their appreciation for Western constitutionalism and tried to employ it against the colonial government in the 1920s. Consequently, Taiwanese had a chance to experience the limited democratic election after 1935, although the mountain indigenous peoples were almost excluded from this development during the Japanese colonial period.

The KMT regime, composed of the elites of Mainlanders, brought Taiwan's people the R.O.C. constitutional structure that had provisions with constitutionalism, but their effectiveness had been denied under the martial law. Those Native Taiwanese who were educated by the Japanese were unable to change this situation. Only a few liberals who came from Republican China could not challenge the authoritarian rule of the KMT because they had not enough support from the general public in Taiwan.

* Distinguished Professor, College of Law, National Taiwan University; Joint Appointment Researcher Fellow, Institute of Taiwan History and Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

The new generation of legal scholars accepting the constitutionalism in postwar Western countries cooperated with the opposition alliance, which were largely Native Taiwanese and became the DPP later on, against the KMT regime in the 1970s and the 1980s. However, the KMT, which was continuously controlled by Mainlander elites, had recruited many Native Taiwanese for elections since the 1970s. As a result, there existed more than one political force, which was significant for the emergence of constitutionalism, in Taiwan. Accordingly, President Lee Teng-hui promoted the liberalization and democratization of Taiwan in the 1990s after the strongman, President Chiang Ching-kuo, died in 1988, and Taiwan finally became a liberal constitutional country when the opposition party, the DPP, won the presidential election in 2000.

The appearance of democracy in Taiwan strongly depended on incessant elections in the past. The constitutional culture that (the) competing parties make compromise to develop common understanding was unfortunately not cultivated in Taiwan. Diverse national identities and struggle for political or economic interests resulted in serious dead-lock(s) in Taiwan, where there were two main social and political force. The KMT led by President Ma Ying-chou became the ruling party in Taiwan again in 2008, with supra-majority seats in the Parliament. That was not beneficial for the liberal constitutionalism in Taiwan, however. Today, Taiwanese people must sincerely learn the fundamental spirit of constitutionalism, and know that the national identity is derived from a citizen's support for the constitutional order of a nation-state.

KEYWORDS: constitutionalism, democracy, constitutional law, human right, nationalism, national identity.

壹、前言

一、問題意識

為了與臺灣的財團法人海峽交流基金會江丙坤會長進行關係到臺灣國家主權事項的會談（通稱「第二次江陳會談」），中國的海峽兩岸關係協會陳雲林會長於2008年11月3日率領該會代表團來到臺灣。在陳雲林先生一行人為期數日的滯臺期間，其所下榻的臺北圓山大飯店周圍，陸續發生多起程度不一的警民衝突事件，並被統稱為「1106圓山事件」¹，不久，多所大學的師生於網路上發起〈1106行動聲明——抗議警察暴力！捍衛自由人權！〉²，而為稍後以學生為主要參與者的「野草莓運動」揭開序幕。圓山事件及野草莓運動等之發生，已涉及當今憲政主義（Constitutionalism，或譯為「立憲主義」）所強調的限制國家權力、保障人民權利等核心價值³。當執政者與抗議者分別以「依法行政」與「警察暴力」，或是

1 於2008年11月19日，臺大法律學院數位教授曾從法學的觀點評論這些事件，當時即統稱為「1106圓山事件」，參見國立臺灣大學法律學院編，從法學觀點論1106圓山事件，國立臺灣大學法律學院院訊，6期，頁2-27（2009年）。亦參見李建良，為「笨總統」上一堂憲法實例課——1106圓山事件案——，台灣法學雜誌，117期，頁1-2（2008年）；黃榮堅，問題不在暴力，問題在正當性，台灣法學雜誌，117期，頁6-9（2008年）；曾韋禎、施曉光、王寓中、邱燕玲、姚介修、林恕暉、洪敏隆，執法粗暴 警察形同公安，自由時報，2008年11月4日A4版；劉慶侯、吳岳修，唱片行播本土樂 警衝入制止，自由時報，2008年11月5日A3版；羅暉智、梁鴻彬、何醒邦、張企群、蔡旻岳、蕭博文，嗆馬園陳 深夜驅離 汽油彈丟鎮暴警，中國時報，2008年11月7日A1版；本報記者，警民流血衝突 十年來最嚴重，中國時報，2008年11月7日A3版；政治新聞中心、社會新聞中心、台北都會新聞組，圍城夜以繼日 警民流血衝突，自由時報，2008年11月7日A1版。

2 李明璁等，1106行動聲明——抗議警察暴力！捍衛自由人權，2008年11月7日，聲明內容及共同發起人名單，<http://1106protestcast.blogspot.com/2008/11/1106.html>（最後瀏覽日：2012年3月18日）。

3 就Constitutionalism一詞，於日治時期，或戰後臺灣某些曾受日本法學影響的學者，例如劉慶瑞、李鴻禧等，即譯為「立憲主義」，但晚近有許多臺灣學者譯為「憲政主義」。由於本文的問題意識來自當下的臺灣，故採用當今較習見的「憲政主義」的譯法，以之觀察發生在過去的歷史事實。其實該等思想剛被傳

以「妨害社會秩序」與「集會自由」、「言論（表現）自由」等相對立的觀點，來詮釋事件中的國家權力行使與人民自由權利時，更反映了當今由臺澎金馬此地域上人民所組成的臺灣社會（society，係相對於國家(state)而言，亦可指自成一格的特定的生活共同體(community)），對於憲政主義及其衍生的生活方式等等自近代西方引進的概念，可能仍存在有認知上差異。

透過法律史研究的觀察，將發現前述所呈現的認知差距，並非僅是出自於共時性(synchronic)的社會結構差異，而是同時與歷時性(diachronic)的分殊經驗積累有關。按前揭衝突的兩造在面對憲政主義時，之所以一方側重國家權力行使，另一方強調人民自由權利，並不是單純地因為身為執政者或異議者的立場，還涉及雙方關於憲法生活方式有其相異的**歷史經驗**。換言之，圓山事件的衝突原因，不僅僅來自當時執政的中國國民黨（以下簡稱「國民黨」）意圖促使「第二次江陳會談」順利進行的強大決心，以及部分臺灣人民對於執政黨如此決心的疑慮或不安。更深層的因素來自於：具有威權統治經驗的國民黨政治菁英於2008年重啟執政後，仍舊以其所熟悉之原存於兩蔣時代（1950-1988年）、尚未出現自由民主生活方式之時的法政經驗和觀念，來套用在自由民主憲政已然出現的當代臺灣社會。其因此與從小體驗1990年代以後自由民主生活的「野草莓」世代之間，存在著不相一致之對憲政主義的認知，衝突自難避免⁴。

如筆者在另文所指出的，源自西方的自由民主憲政係出於歷史的巧合，而實現於當代的臺灣共同體⁵。而在該歷史發展過程中，

入東亞及臺灣時，較常被譯為「立憲主義」，筆者以往在文章中亦使用此。當今有關憲政主義的內涵及譯名，參見林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞編著，*憲法——權力分立*，2版，頁11-12（2009年）；李鴻禧，*憲法與憲政*，頁3、7（1997年）。

4 參見王泰升，*具有歷史思維的法學——結合台灣法律社會史與法律論證*，頁84（2010年）。

5 就這項論點，參見王泰升，*自由民主憲政在台灣的實現——一個歷史的巧合*，

也一直存在著朝野對於憲政主義各自表述，甚或執政者刻意曲解的現象。為了釐清當前臺灣社會在深化自由民主憲政時所面臨的問題，實有必要先省視西方憲政主義進入臺灣社會的整個歷史過程。至於應持何種法學論述以進一步貫徹自由民主憲政的理念，或許援用西方的學說理論是方法之一，但本文嘗試從臺灣社會自身的問題情境／發展歷程，來構思適切可行的方案。因此，文末將提出「具有歷史思維」的一得之愚，以供臺灣人民參考。

二、研究對象

有鑑於主張以具體的憲法規範來限制國家權力行使、保障人民權利的憲政主義，係位於歐、美等地的西方社會於17、18世紀以降所發展出的政治理念⁶，故在探索此一概念進入臺灣社會的歷史過程時，首先必須認識到，隨著時間與地域的不同，各該西方社會所構思的憲政主義理念的實質內涵，亦存有認知上的差異。於今臺灣的法學界有關憲政主義的通說，在歐美恐怕也是二次世界大戰後方成為主流的學說。其次，前述孕育於西方社會的憲政主義理念，可能當時在西方即存有不同於今之內涵，或者在輾轉進入到臺灣社會的過程中，夾雜有引介者的主觀想像或目的，以致遭無意的誤解或經有意的篩選。過去日文或華文文獻之以漢字將此等思想譯為「立憲主義」，多少是因為當時所強調的是，樹立憲法作為國家法政生活的最高準繩，以對照東亞傳統上之以政治權威個人的命令作為國家統治行為最高指令，而較不注重權力分立與人權保障等憲政內涵。是以，本文在敘述日治時期的憲政發展時，將併用「立憲主義」一詞。

作為憲法史論述的一環，為使研究對象更加貼近其所在的歷史現場，在以下的論述中，將採取所謂「固有意義之憲法」的定義方

臺灣史研究，11卷1期，頁167-224（2004年）。

⁶ 參見李鴻禧（註3），頁4-5。

式。亦即，凡涉及政治權力之運作、高層次機關之組織結構，或國民與國家之關係的根本性法規範，皆認定為是「憲法」，其表現形式不限於以憲法為名的單一法典，而可能分別由數個具實質憲法內容之法規範所構成⁷。同時，為解析臺灣社會所曾接觸過的各種自認或被認為是「憲政主義」的主張或法制，在此係以近代西方發展出憲政主義之後，一般認為其在內涵上最核心的要求：（一）國家統治權須依憲法之規定行使、（二）國家權力須分立，以及（三）人民基本權利須受保障等，作為一種可稱為「理想型」的概念工具，以辨識是否屬於憲政主義的主張或法制。藉此來描述，而非評價既存的歷史事實（含規範事實）。

此外，本文所欲探究的動態歷史過程，也非僅止於觀念上的西方憲政主義、乃至於形式上的現代型憲法規範如何被移植進入臺灣共同體的途徑，還希望能關注此等「舶來品」於輸入後與臺灣社會的互動，亦即其現實上被社會一般人所接納遵行或排拒規避的整個歷程。基於這項認識目的，在此擬觀察前述互動過程中的各類行動者(actors)，諸如政治菁英、法學者、法律專業社群、執法官員，以及一般人民⁸，對於「憲政主義」的認知與理解，冀能探知來自西方的憲政主義與臺灣社會的實際互動狀況。因此以下將以人們對憲法的認知等文化觀念的探討為主，筆者曾為文討論過的各個時代國家實證法規範內容則僅供輔佐之用。當然，隨著所探討之時期的推移，本文所指稱的臺灣社會（共同體）的組成、乃至於身居其間的行動者，容或有所不同。

7 在此憲法史觀點下的「憲法」定義，亦參見王泰升，台灣日治時期憲法史初探，收於：台灣法律史的建立，2版，頁187（2006年）。

8 有關法律規範體系與臺灣社會的互動歷程、及其中所可能涉及的行動者，亦參見王泰升（註4），頁4，「圖1-1：從法條到法社會發展歷程及其可能的互動示意圖」。

貳、日本殖民統治下的憲政主義初體驗

一、伴隨憲法爭議而來的憲政主義概念

日本帝國於1895年透過國際條約而取得對臺灣（臺澎）的主權後，隨即就因對臺灣的統治架構問題，引發一連串涉及帝國憲法應否適用於臺灣的爭議，也為臺灣社會與西方憲政主義之間的互動揭開序幕。不過，清日兩國關於臺灣統治權威之替換並未顧及在地住民意見，清朝在臺灣的地方政府官員雖曾創立貌似立憲國家的「臺灣民主國」，但迅即敗亡⁹。因而其後能夠代表臺灣社會（作為一個生活共同體，於日治時期限於臺澎，尚不及國民黨統治時期所涵蓋的金馬）參與這場有關憲政主義初體驗的行動者，起初並非原本居住於臺灣的人民，而是1895年新加入臺灣共同體的日本統治者，甚至其進行論爭的地點乃是遠離臺灣的日本帝都東京。按作為日本帝國新附領土的臺灣，應否被納入立憲主義憲法的施行範圍內，亦即當時日本的憲法應否施行於臺灣的憲法上爭議，如下所述，係發軔於Michel Joseph Roven與William Montague Hammett Kirkwood等二位外籍法律顧問，於1895年4月間先後呈送給日本帝國政府的意見書。

處理日本本國的憲政議題，卻需要諮詢來自西方的外國法律專家，有力地說明了憲政主義對於包括日本人在內之東亞人民的外來性。1895年時日本明治政府須做決定的是，應否就臺灣另創一套有別於內地的統治體制，以因應當地統治上的特殊需求？由於日本已

⁹ 臺灣民主國在中央政府組織上，設有掌理內務、國防外交的「總統」，但其僅存續13天，並設置有權訂立律例章程、由住民選出之代表所組成的「議院」，但其從未開過會。雖自立為主權國家，卻又表示對於清朝「恭奉正朔、遙作屏藩」。創建者雖套用「共和國」等近代西方法概念包裝其政治行為，然並不瞭解其真義，更無獨立建國之意志力與行動力，故臺灣民主國僅是曇花一現爾。參見王泰升、薛化元、黃世杰編著，*追尋臺灣法律的足跡——事件百選與法律史研究*，頁62-63（2006年）。

在1889年公布、隔年施行採君主立憲制的《大日本帝國憲法》（即學界通稱為「明治憲法」），該憲法無論制定動機是什麼，此時已成為統治國家必要的「道具」，故在施行憲法的地域即須遵從憲法所規定之統治權行使方式，以在形式上符合立憲主義的要求。據此，倘若臺灣在該憲法之施行地域內，即不得對臺灣另創一套為該憲法所不允許的統治體制。對於作為前提性問題的臺灣施行憲法與否，涉及新頒佈的本國憲法之解釋適用，日本政府卻就教於外國籍法律顧問，原因就是其較熟悉本國憲法所立基的西方憲政主義。但法律應如何為解釋適用，並不像算術題目一樣有唯一的標準答案，不同國籍的法律顧問經常背負著不同國家的法律文化與經驗。法籍的法律顧問Roven認為為了長遠治理計，仍宜援引法國統治阿爾及利亞的經驗，使臺灣將來成為帝國內一個縣，漸次施行與內地一致的憲政體制。英籍的法律顧問Kirkwood則參照英國「君主直轄殖民地」的模式，認為天皇可直接以天皇大權，來治理非屬憲法施行地域的臺灣，故天皇之將包括立法權力在內的統治權委託給殖民地政府來執行，並不違憲¹⁰。

面對兩位外籍顧問的不同建議，時任內閣總理大臣的伊藤博文先是在1895年5月以訓令方式，賦予新任臺灣總督樺山資紀「臨機專行」的權力，並於訓令中表示日本政府將待臺灣總督所提出的詳細調查報告後，再行確定適合於臺灣的永久性制度¹¹。同年6月，由內閣所設置的「臺灣事務局」在日軍進入臺北城後，於舉行始政式前開會討論前揭兩位顧問的建議時，大多數的成員基於「日本與臺灣在血緣、文化上的近似性」，且為了「避免英國式殖民地統治所意涵的白人剝削亞非有色人種的負面形象」等理由¹²，傾向於支持

10 在此亦參考Kirkwood於1895年7月24日再次提出的法律意見書。參見伊藤博文編，臺灣資料，頁78-107、148、399-409（1936年）。

11 參見伊藤博文編（註10），頁434-439。

12 這些理由係由時為臺灣事務局成員之一的原敬所提出。參見伊藤博文編（註10），頁32-34；Edward I-te Chen, *The Attempt to Integrate the Empire: Legal*

法籍顧問的意見。然而，日軍從臺北地區再往南前進即遭遇臺灣人激烈的武裝反抗，臺灣總督府因此以「俾能有效統治近三百萬與日人習俗不同，且對日本帝國忠誠度可疑的台灣住民」為由¹³，讓日本中央政府與帝國議會同意將對臺灣的立法權力委託給臺灣總督，而於1896年3月底通過《有關應施行於臺灣之法令的法律》（因以法律第63號公布，故世稱「六三法」）。換言之，日本明治政府就兩個各自可得到某種憲法解釋支持的方案，係以實際上的統治需求為準而為選擇。

其實在明治憲政體制下，違憲解釋只能被用於帝國議會等政治場域上的批判，而不具有法律效力上的意義。按六三法在結論上採取英籍顧問所建議之將對臺灣的立法權力委任給在地總督¹⁴，該顧問早已預期這樣一來將導致立法權遭受傷害的帝國議會反彈¹⁵，也因此六三法附有3年期限（1906年制定的「三一法」則有5年期限，直到1921年制定的「法三號」才沒附期限），當期限即將屆滿需要再延長時，關於臺灣是否施行明治憲法、總督委任立法權（律令權）是否違反憲法等憲法上爭議，就一再出現於作為政治場域的帝國議會內，而政府部門也經常需釋出利益以換取議員的支持延期¹⁶。此外，戰前日本憲法學界也熱烈地投入這項憲法爭議的討論¹⁷。然而明治憲法上並無司法違憲審查制度，當時日本的憲政運作上亦欠缺專責的釋憲機關，故違憲的法律在國家的實證法上仍屬有效施行¹⁸，違憲的實務運作也往往得以「慣例」為由得獲承

Perspective, in THE JAPANESE COLONIAL EMPIRE, 1895 – 1945, at 240, 250-51 (Ramon H. Myers & Mark R. Peattie eds., 1984).

13 參見Chen, *supra* note 12, at 247.

14 不過，臺灣總督據此委任發佈律令時，仍須經中央政府內閣議決送請天皇為勅裁方可，非可為所欲為，況且臺灣總督也是由中央政府所任命。

15 參見伊藤博文編（註10），頁105；王泰升，台灣近代憲政文化的形成——以文本分析為中心，臺大法學論叢，36卷3期，頁6（2007年）。

16 參見王泰升（註7），頁206-208。

17 各式各樣的主張及對之所做的評釋，參見王泰升（註7），頁190-205。

18 參見有賀長雄，國法學（上冊），頁561（1901年）。

認¹⁹。法學者引經據典所做的各種憲法解釋，似乎只為日本帝國政界增添更多政治論爭的根據。

不過，這些憲法論爭能在政界發揮一定的功效，也說明日本明治政府相當在意形式上的合憲性，故盡可能以合憲的外觀包裝其政治意圖。1896年時，代表政府在帝國議會答詢的臺灣總督府民政長官水野遵，面對六三法上總督律令制定權牴觸帝國憲法的質疑，起初回答：「此全然與憲法無關係，憲法尚未全部施行於臺灣，即憲法的效力不及於臺灣。」，但在受到議員批判後隨即改口為：「憲法並未全部施行。換言之，憲法中關於臣民權利義務之規定實際上未施行，但憲法上有關天皇大權者，則已施行於臺灣。²⁰」可見憲法縱令只是統治「道具」，還是有一定意義。因此1899年政府代表在帝國議會為答詢時，即曾以憲法是適用於臺灣作為前提，承認臺灣總督府法院判官之身分受憲法上相關規定的保障²¹。其實採取明治憲法已施行臺灣的說法，可搏得全國一致施行憲法的美名，憲法上所要求之立法事項應經帝國議會協贊，在形式上已以六三法（法律）的制定而遵守之，在實質上卻已幾乎是由中央及臺灣行政部門掌握臺灣立法事項（雖帝國議會仍可直接對臺灣事務立法），無礙於對臺統治的方便性。無怪乎，1906年時任內務大臣的原敬於帝國議會審議《有關應施行於臺灣之法令的法律》（即前述「三一法」，蓋此次審議後的內容係以當年的法律第31號公布）時，就是以規範委任立法體制的六三法係依憲法規定經帝國議會協贊為由，主張十餘年來憲法一直施行於臺灣²²。到了1921年帝國議會最後一次審議

19 參見佐々木惣一，日本憲法要論，3版，頁608（1932年）。

20 參見內閣記錄課編，臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律其ノ沿革並現行律令，頁4、6（1915年）。

21 參見臺灣總督府警務局編，臺灣總督府警察沿革誌第二編：領臺以後の治安狀況（下卷），頁14（1942年）。

22 參見內閣記錄課編（註20），頁250；以及外務省條約局編，日本統治下五十年の台灣（「外地法制誌」第三部の三），復刻版，頁39（1990年）；另曾任臺灣總督府高等法院檢察官的三好一八，有謂樺山總督時代（1895年5月10日至

《有關應施行於臺灣之法令的法律》（即前述「法三號」，蓋其後以當年的法律第3號公布）時²³，時任臺灣總督的田健治郎及其總務長官下村宏皆明白答稱憲法效力及於臺灣且總督的委任立法權不違憲²⁴。然而，誠如日治晚期在臺北帝國大學文政學部政學科（即今國立臺灣大學法律學院前身）任教的園部敏所指出的：「所謂明治憲法當然施行於臺灣，只是一種形式的、概括的論斷。²⁵」

縱令明治憲法得以毫無限制地完整施行於臺灣，也未必意味著臺灣社會得以藉其內容一窺當時西方憲政主義的全貌。由於制定當時的政治角力與相互妥協，明治憲法未以英、法那般側重自由民主憲政主義的憲法，而係以強調君權、形式法治、且深具絕對主義色彩的德國式憲法，作為繼受的藍本²⁶。故其中對於西方憲政主義的選擇與引進，乃是由政治支配階層在其所需要的範圍內加以利用，且僅僅模仿其外形²⁷。因此，明治憲法尚未能全然符合西方憲政主義所強調的人權保障目的²⁸，而當中諸如強調天皇的大權、或是欠缺對於內閣的規範，在在皆說明其所採擇的是「僅具有外觀的立憲主義」²⁹。

總之，對於臺灣總督府和帝國的中央行政機關等殖民地統治者

1896年6月2日）曾發布憲法已施行於臺灣的內訓，惟筆者尚未尋見此項內訓。參見三好一八，獨立せる臺灣の司法，臺法月報，13卷8號，頁62（1919年）。

23 歷次《有關應施行於臺灣之法令的法律》（即1896年的《六三法》、1906年的《三一法》，以及1921年的《法三號》）的制定過程與內容比較，參見王泰升，日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」，收於：台灣法律史的建立，2版，頁104-114（2006年）。

24 參見臺灣總督府官房審議室編，律令制度ノ沿革，頁126、182（1940年）。

25 園部敏認為：「所謂法治國的具體要素在臺灣法制上仍弱。即第一、立憲主義的實行還不完全。於臺灣欠缺立法權與行政權的分離，……一般私人的自由權利之保障薄弱，……第二、行政法規不完備。……第三，行政爭訟制度的不備。」參見園部敏，行政法概論——特に臺灣行政法規を顧慮して——，改訂版，頁26-29（1943年）。

26 參見坂野潤治著，鍾淑敏譯，近代日本政治史，頁49-53、61-69（2008年）。

27 參見家永三郎，日本近代憲法思想史研究，頁21（1967年）。

28 其詳，參見李鴻禧（註3），頁26-29。

29 參見大石真，日本憲法史，2版，頁296（2005年）。

而言，只要在形式上依循憲法的立法程序，使六三法等可資援用的規範得以完備，即屬合憲。主張違憲者的立論，不管是基於法理論或出於純粹的政治鬥爭，其所設想的解決之道，同樣都指向形式上的規範增補（無論是就憲法典內容的增補倡議，或是對新法案的審議與改訂），而未顧及殖民地人民依西方憲政主義應擁有的權益³⁰。至於無緣參與這場爭議之在臺灣的漢人，似乎只能透過表達諸如「法網愈密，規約愈加」³¹，這般從外觀上發覺到法規範數目已增多，來認識此時由殖民統治者所建構的形式主義立憲體制。

從宏觀的歷史角度來看，被當成是「啞巴」與「局外人」的臺灣共同體人民，就從19世紀末展開了橫跨三個世紀（直到21世紀初），爭取為自己的憲政生活方式發言、並要求自我決定(self-determination)的漫漫長途。首次堪稱具有重大突破性的發展，即是下述日治中期訴諸西方憲政主義的政治反對運動。

二、西方憲政主義的在地實踐：以臺灣議會請願運動為例

除了來臺任官者外，在日治時期新近加入臺灣社會的成員還包括移居自日本內地的一般人民。按原已居住於臺灣、屬於漢族或被漢化之平埔族的臺灣人（當時法律稱「本島人」），在日治之初對於西方憲政主義幾乎一無所知。而這批可稱為「在臺日本人」（當時法律稱「內地人」）的新住民，雖僅在日本內地經歷短短數年的憲政生活，卻仍得透過語言使用上的優勢，探知各種基於殖民地治理而生的憲法爭議，甚至得以一如帝國議會內的政治爭鬥般，試圖透過不具實質法律效果的各種違憲主張，來爭取或護衛其自身的利

³⁰ 參見王泰升（註7），頁204-205。

³¹ 語出時任下南坑第一保保正（自1899年起）的張麗俊，於其1906年2月14日的日記中的記載：「雨天，在家錄書類存照簿。是舉也，因自明治三十二年任本庄第一保正之責以來，迄今歷七星霜，三年前雖有保正之名，尚少保正之事；三年後法網愈密，規約愈加，是無大小，屬保正之責者，難以枚舉……」。見張麗俊著，許雪姬、洪秋芬解讀，水竹居主人日記（一），頁14（2000年）。

益。例如，某些在野的在臺日本人（包括有退職檢察官、新聞記者、辯護士等）指摘《臺灣新聞紙條例》拘束其言論自由，或主張《臺灣保安規則》之將內地人驅離島外、禁住臺灣1至3年的處分有違遷徙自由。然而彼等並未擁有足以和臺灣總督府進行抗衡或交涉的政治實力，且所提出的違憲主張乃至所訴求的利益內涵，均未能引發同屬被統治者、人口占絕大多數的臺灣人的共鳴與支持³²，故終究不能撼動臺灣總督府著重形式法治、「依法」（依據前述被批評為違憲的律令）打壓異己的威權統治。

到了1920年代時，許多年輕的臺灣人菁英在掌握日本統治者所帶來的語言及知識後，面對統治者已然做出「憲法一直施行於臺灣」的宣稱，加上號稱「大正民主」的帝國政治氛圍下，開始援用明治憲法的內容，追求其個人以及整個臺灣人群體的利益。這些臺灣人菁英一方面引用明治憲法的條文來做為法律上主張的依據，另一方面也嘗試經由明治憲法以外的途徑，直接探索西方憲政主義的內涵³³。其因此不僅認為當時的臺灣稱不上實施憲政，甚至還主張當時的日本內地也不過僅是實施以「憲政」為幌子的「似是而非的立憲政治」³⁴。不過在實踐活動上，他們相當程度是在既有法律體制內尋求改革，故認為「凡對異民族的特別統治，總督為代表主權者的不可缺之機關……。所以我們對於總督制非贊成撤廢，而要求總督治下的特別立憲政治」³⁵。換言之，這群臺灣人菁英並不反對

32 參見王泰升（註5），頁182-183。由於語言不通，再加上並未居住在一起，在臺灣的日本人與臺灣人之間幾乎沒有什麼共同的生活經驗，從而在臺日本人亦難以瞭解臺灣人的心聲。例如關於《臺灣新聞紙條例》拘束言論自由的指摘，對於在日治初期沒人辦報紙、也少有人閱讀日文報紙的臺灣人，恐怕沒什麼感覺吧！

33 這些臺灣人菁英對於西方立憲主義的內涵描述，可參見王泰升（註7），頁235-241。

34 參見臺灣民報社編輯，社說 似是而非的立憲政治 大失統治的能力，1927年3月6日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯，臺灣民報社論，頁407-408（1992年）。

35 參見臺灣民報社編輯，社說 政治自治與經濟自主，1927年6月26日1版，收

臺灣因在日本帝國內作為「殖民地」而有的總督制度，但要求關於臺灣的法制能實現更多西方憲政主義精神，且超越明治憲法條文的框架，其因此如下所述，追求憲法上未明定之帶有殖民地議會性格的「臺灣議會」。

臺灣議會設置請願運動（以下簡稱「議會請願運動」）的生成及發展，見證了當時許多臺灣人菁英與西方憲政主義思想的首度相遇。在此所討論的議會請願運動，係指以林獻堂為中心的一群臺灣人菁英，於1921年至1934年間，為訴求設置臺灣議會（亦即「殖民地議會」）而向帝國議會所提出總計15次的請願活動。其間受到諸如臺灣文化協會或臺灣民眾黨等堪稱臺灣當時最有力的團體支持，奠定以臺灣為本位的政治運動立場，也為臺灣民眾喚起了政治、社會，乃至於文化的意識³⁶。

在1921年第1回的〈臺灣議會設置請願書〉的「請願之旨趣」中，開宗明義地表示：「謹按大日本帝國、為立憲法治國、臺灣乃隸屬於帝國版圖之一部。故在臺灣統治上、認為須設特別制度之範圍內、務宜準據立憲政治之原則、固屬當然之理。然按臺灣統治制度、……使行政立法二權、掌握於同一之統治機關、……誠宜參酌特殊之事情、鑑世界之潮流、徵民心之趨向、宜速準據立憲之本義、故須順應臺灣事情之立法、即就臺灣住民公選議員組織臺灣議會以行之、以補帝國議會之所不能為者」³⁷。從這段論述可知，當時從事議會請願運動的這些臺灣人菁英，業已肯認明治憲法施行於

於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁439。

³⁶ 參見許雪姬等著，臺灣歷史辭典，頁1179（2004年）；另亦參見王泰升（註7），頁232-234、241-242。擬議中的「臺灣議會」是由居住於臺灣的本島人（臺灣人）與內地人選舉產生，但似乎排除了當時被稱為「蕃族」的高山族原住民族。

³⁷ 此一〈臺灣議會設置請願書〉的完整全文參見記者（即林呈祿），就臺灣議會設置之請願而言，臺灣青年，2卷2號，漢文之部，頁20-25（1921年）。其後第二、三回請願書內容與此大同小異，分別參見編輯員，臺灣議會設置請願に就て，臺灣，3年1號，和文之部，頁30-31（1922年）；以及編輯員，第三回臺灣議會設置請願，臺灣，4年3號，和文之部，頁2-4（1923年）。

臺灣以及自六三法以來的臺灣特別法制，且為了達成「擁護伸張臺灣住民之權利與義務」的目標³⁸，乃以該等國家實證法作為議會請願運動的基礎，進而嘗試訴諸某些未必來自於明治憲法、但毋寧更符合西方思潮的「有納稅必有參政的憲政常理，又是現代文明國確定不易的立憲公理」³⁹。這些憲政思想在議會請願運動期間，不斷透過諸如《臺灣》或《臺灣民報》與《臺灣新民報》的社論⁴⁰，向臺灣社會的知識階層進行傳播。

38 參見林慈舟（即林呈祿），六三問題之運命，臺灣青年，1卷5號，漢文之部，頁26（1920年）。林呈祿對此問題的思考，也意味著接受近代西方法政思想熏陶的第一代臺灣人知識份子，開始本於臺灣主體意識來思考臺灣的憲政制度。

39 參見臺灣民報社編輯，社說 臺灣議會與臺灣憲法，1927年1月30日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁397。

40 登載在《臺灣》雜誌的相關評論包括有下列各文：臺灣雜誌社編輯，世界改造と臺灣人の自覺，臺灣，4年1號，和文之部，頁1（1923年），收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁53-54；臺灣雜誌社編輯，必現すべき臺灣議會，4年3號，和文之部，頁1（1923年），收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁57-58；以及臺灣雜誌社編輯，臺灣議會促進の聲，5年1號，頁1（1924年），收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁67-68。而在《臺灣民報》中，與此相關的「社說」（即社論）則有：臺灣民報社編輯，社說 偽造民意假公行私，1924年7月21日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁129-131；臺灣民報社編輯，社說 確信臺灣議會設置的實現，1925年2月1日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁179-180；臺灣民報社編輯，社說 臺灣議會與日本國民，1926年2月21日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁299-300；臺灣民報社編輯，社說 唯有臺灣議會的一路，1926年12月12日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁383-384；臺灣民報社編輯，社說 臺灣議會與臺灣憲法，1927年1月30日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁397-398；臺灣民報社編輯，社說 政治的第一工作 須由自治議會做起，1927年11月6日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁475-476；臺灣民報社編輯，元日更新局勢，1928年1月1日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁493-494；臺灣民報社編輯，社說 日本普選實施與臺灣自治，1928年1月29日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁501-503；臺灣民報社編輯，社說 政治運動的目標 無產政黨援助與臺灣議會運動，1928年2月5日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁505-506；以及臺灣民報社編輯，社說 外攻內應的地方自治完成運動 總望民眾合力要求，1928年4月29日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁529-530。至於《臺灣新民報》的部份，則有：臺灣新民報社編輯，社說 政治季節到了 社會有心人豈可不奮起，1930年12月6日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁847-848；以及臺灣新民報社編輯，社說 政治時期將到 植民地人的叫聲，1931年10月24日2版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁939-940。

面對依循明治憲政體制所發起議會請願運動，時任臺灣總督的田健治郎於1922年12月25日，向前來請示應如何勸止蔡培火與蔣渭水等人倡導議會請願運動的警務局長竹內友次郎，指示：「此事從來向林獻堂之來談，說帝國憲法不容二個之帝國議會之精神，戒其輕舉徒勞。所以予斷然不制止之理者，以請願係憲法所許臣民權利之故也。故對此二人，友誼的勸止之則可，以職權制止之則不可矣。⁴¹」從這項言談可知，日本在臺統治階層至少已受到國家實證法中存有「憲法所許臣民權利」之拘束，故不敢認定臺灣政治異議者之請願運動為非法，這不能不說是立憲理念最初步的實現。不過，其用以評斷請願內容者，仍是如「帝國憲法不容二個之帝國議會」等形式上的明治憲法架構，而不關心設置議會的主張是否符合如「國家權力分立」、甚或是「保障人民基本權利」等西方憲政主義所主張的實質內涵。或許之所以「不關心」，就是因為日本統治階層心裡很明白該憲政主義中的「自由」將被用來排除其所擁有的「國家」的干涉、「民主」則將被用來要求參政或制衡行政部門。

日本統治階層更在乎的，可能是議會請願運動所蘊含的臺灣國族主義（Nationalism，當時譯為「民族主義」）的精神。若倡議中的臺灣議會獲得實現，其不僅將得以監督臺灣總督府的律令權及預算權，也將某程度瓜分帝國議會的立法權。對此，臺灣總督府與帝國議會之所以特別關注、從而否決臺灣議會之設置，不全然是因為其權力將因而受到制衡或瓜分，而毋寧更擔心這般監督與分權，將導致殖民地自治或民族自決的可能結果⁴²。蓋一旦殖民地議會被設置，難保其不會要求更多的自主立法權，甚至爭取總督之民選，以形成日本帝國內的自治殖民地，例如大英帝國內的加拿大、澳大利

41 參見吳文星、廣瀨順皓、黃紹恆、鍾淑敏編，臺灣總督田健治郎日記（下），頁229（2009年）。

42 參見《植民》雜誌八月號著，錫舟（即王敏川）譯，臺灣議會設置請願懇談記，臺灣民報，1924年9月21日11版；今川義夫著，錫舟（即王敏川）譯，臺灣議會問題的正解，臺灣民報，1925年1月11日10版。

亞、紐西蘭。亦可能經由憲政主義而朝向國族主義發展，就如後來加、澳、紐之成為主權獨立的國族國家。因此，在帝國議會內縱使有人基於對立憲主義訴求的關心，而組成臺灣參政問題調查會⁴³，卻終究難以在自治主義訴求下贊同設置臺灣議會。帝國議會尚且如此，更遑論向來在殖民地壓制人民之主張民主的臺灣總督府了⁴⁴。值得注意的是，來自西方的憲政主義在臺灣的被統治階層間開始流傳時，就已經存有促成國族主義的微妙關係，此關連性不但延續至戰後，甚至如文末所述，於今猶存。

儘管議會請願運動被視為是以臺灣人為本位（亦即「臺灣是臺灣人的臺灣」）的政治運動，但並非所有的臺灣人菁英皆能同意這一群人基於西方憲政主義所揭示的主張。首先，由於「臺灣人意識」係在臺漢人因居住於被稱為「臺灣」之特定地域、又將種族文化有別的在臺日本人群體視為「他者」後，才逐漸產生的一種集體認同，在為時尚短的形成過程中，人們對於「臺灣人本位」不一定存有強烈的情感。在得以獲取現實的經濟或政治利益的考量下，唯總督府之命是從的臺灣人更是不乏其人，例如作為日本統治協力者的「有力者大會」政治菁英諸君，便依循著臺灣總督府的反對意見，提出臺灣沒人才、人民程度不足，或時機尚早等理由來反對臺灣議會的設置倡議⁴⁵。又，雖有不少習法的臺灣人參與甚至主導議

43 參見臺灣民報社編輯，臺灣參政可否之調查，臺灣民報，1924年7月21日3版。

44 譬如1927年5月間臺灣民黨被禁一事，即因其黨綱所示的「臺灣人全體」一詞帶有民族自治自決的意思，參見臺灣民報社編輯，臺灣民黨的廢止理由 當局的用意令人費解，臺灣民報，1927年6月19日2版。故後來成立的臺灣民眾黨不敢明白表明自治主義的立場，且黨綱內亦無揭示設置臺灣議會的要求。參見臺灣民報社編輯，臺灣民眾黨 開中央委員會決定黨綱的說明，臺灣民報，1927年11月13日3版。

45 身為「有力者」的臺灣人政治菁英們所提出的反對意見，參見蔡一舟，關於請願臺灣議會敬告島內同胞，臺灣，4年1號，漢文之部，頁4（1923年）；臺灣民報社編輯，辜顯榮君的時事談，臺灣民報，1923年8月1日10版；臺灣民報社編輯，辜君演說的大要，臺灣民報，1卷5號，1923年8月1日10-12版；以及臺灣民報社編輯，社說 這是誰的善變呢？，1924年8月11日1版，收於：吳密察、吳瑞雲編譯（註34），頁135-136。

會請願運動，但亦有臺灣人辯護士提出設置臺灣議會係屬違憲的見解⁴⁶。

不過，這項憲政上訴求，卻因總督府的打壓以及運動領導者在臺灣人社會中具有一定的聲望，而傳播至不少臺灣民眾心中。當日日本內地警方獲准設立的「臺灣議會期成同盟會」在臺灣從事活動，卻在1923年時被臺灣總督府法院的檢察官以違反《治安警察法》為由而起訴。就在民眾熱情旁聽的公開審判庭上，議會請願運動是否違憲成為法庭辯論焦點之一。隨著被告們的無罪宣判、或僅以結社行為而被判刑至多四個月有期徒刑，不但一般民眾有機會上到「憲法課」，還使得輿論界不敢再隨意指摘其違憲；而從事運動者入獄時民眾爭相送行，及其後請願簽署人的人數大增，都足以說明不少臺灣人已因該事件而接觸或支持某些憲政主義思想⁴⁷。

前述這群從事議會請願運動的臺灣人菁英，對於追求立憲政治的相關知識，十分具有熱誠。從原欲設於臺北的「臺灣議會期成同盟會」遭殖民地政府禁止設立後，該會成員即改向東京的警察機關提出設立申請並獲准設立，可知1920年代的臺灣人菁英對於日本內地的政治生活方式，已有相當程度的掌握。而當有機會進行海外留學或國際旅遊時，臺灣人菁英對於西方憲政主義的認知，勢必也將超溢於日本或明治憲法的範疇之外。以大力支持議會請願運動的林獻堂為例，縱使其實踐訴求的手段不能跳脫臺灣總督府所設定的框架⁴⁸，然而，當其得於1927-1928年間遂行環球旅行壯舉時，也不忘

46 參見陳鈺雄，日治時期的台灣法曹——以國家為中心之歷史考察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁212註56（1996年）。

47 此即臺灣史上所謂的「治警事件」，但當時《臺灣民報》常逕稱「台議事件」，若以事件性質而言該稱呼十分恰當，且有鑑於依該法所起訴之案件不只這件，故實以稱「臺灣議會事件」為當。參見周婉窈，日據時代的臺灣議會設置請願運動，頁81-88（1989年）。

48 其中最常見的方式便是透過與總督的會面直接陳言。於今藉由田健治郎的日記，可得知其與諸如林獻堂這般臺灣知名士紳不乏直接互動的機會，而林獻堂也曾就議會請願一事，直接「乞教」於總督，或先行向總督報告其「將以明後日上京，從事於昨年來繼續臺灣議會請願之事」、「陳辨臺灣議會設立請願再提

就近考察各國的獨立建國歷程、自治運動，或是議會民主等實況，並及時於《臺灣民報》上撰文⁴⁹、或是在事後透過公開的演說⁵⁰，來傳播這些海外見聞。

不容諱言的是，西方憲政主義並非當時所有臺灣人政治異議者一致的信念。對於具有社會主義傾向的臺灣人知識份子而言，基於西方憲政主義而來的議會設置倡議，終究不脫資產階級的思考模式。在強調唯有透過無產階級革命運動的手段方能解放全體臺灣人的意識形態下⁵¹，這群社會主義者縱使同意殖民地民族自決的重要性，卻仍反對此向日本統治者叩頭式的議會請願運動，也不稀罕得到統治者所不願施捨的立憲體制。

綜觀前述臺灣人菁英擷取西方憲政主義知識的來源、乃至於檢視其對西方憲政主義實質內容所為的論述，可知這群菁英對於憲政主義的理解，並未止於形式上的施行憲法與國家權力分立（含法律與命令之別），而更涉及對於人民基本權利的實質上保障。然而，受限於統治當局的壓制，這般對於西方憲政主義相當深刻的認知，或許得以啟發不少知識份子，卻未必得以充分對普羅大眾發揮作用，即令有如「臺灣議會事件」這般特定事件的刺激，或有如林獻堂般積極向社會大眾推廣西方憲政主義內涵的人物存在，對當時整個臺灣社會所能造成影響的程度仍舊有限。

出之事情」。參見吳文星、廣瀨順皓、黃紹恆、鍾淑敏編，臺灣總督田健治郎日記（中），頁116、434-435、475（2006年）。關於林獻堂與田健治郎於議會請願運動一事的互動狀況，參見周婉窈，臺灣議會設置請願運動再探討，台灣史料研究，37號，頁13-15（2011年）。

49 關於林獻堂的《環球遊記》內容，可另參見林獻堂先生紀念集編纂委員會編，林獻堂先生紀念集卷二——遺著（1974年）。原文自1927年8月起，於《臺灣民報》上進行連載，並自1930年3月起，改連載於由《臺灣民報》所改名的《臺灣新民報》上，並於1931年10月完結。

50 參見許雪姬，林獻堂著《環球遊記》研究，臺灣文獻，49卷2期，頁13-14（1998年）。

51 參見秀湖生，臺灣議會與無產階級解放，臺灣，4年7號，和文之部，頁43-48（1923年）。

三、缺席的行動者：高山族原住民族

居住於日本帝國統治下臺灣的人們，雖然同樣是日本帝國法律上的「臺灣地域」、政治上的「殖民地」的成員，但因其在法律上被劃分為不同類之人、且有相異的法律上待遇，以致彼此之間不一定具有「共同感」。前述推動設置臺灣議會之屬於漢族或被漢化之平埔族的臺灣人，在建構「臺灣議會」成員時納入了在臺日本人，卻排除了高山族原住民（當時法律稱「生蕃」、「蕃人」、「高砂族」）。事實上高山族原住民族與西方憲政主義的關係，不同於上述的在臺日本人以及臺灣人，故有如下特別探討的必要。

日本在臺統治階層當然不能無視於這群生活在其轄區（臺灣地域）內的住民。在形式上帶入立憲政體的日本在臺統治階層，對於高山族原住民族首先須處理之最根本的法律議題是：彼等是否為日本國國民？具體的說，1895年清、日兩國間關於臺灣主權移轉的國際條約，是否已使得高山族原住民無條件地成為日本帝國的臣民？對此，日本明治政府沒有像對待臺灣漢人那樣大張旗鼓地向來自西方的法律顧問請教，而是由臺灣總督府所支持的《臺灣慣習記事》雜誌，於1906年向日本自己人推出以「生蕃人的國法上地位」為題的徵文比賽⁵²。

就像日治初期的臺灣漢人一樣，牽涉到高山族原住民族與日本明治憲法之關係的論述，並不是由被規範之人發聲，而是由作為統治階層的在臺日本人做成。於前揭徵文比賽中獲得三等獎的辯護士岡野才太郎主張，只要在形式上符合馬關條約所稱：「於兩年猶豫期間未離開臺灣者即視為日本帝國臣民」，以及1897年民內第39號通達《臺灣住民身分處理辦法》第1條規定：「於明治28年〔按：

⁵² 在此之前，應邀參與調查臺灣漢人舊慣與番族習慣的法學者岡松參太郎，和擔任殖民地技術官僚的持地六三郎，皆已曾對此議題表示過見解。參見王泰升，日治時期高山族原住民族的現代法治初體驗——以關於惡行的制裁為中心，臺大法學論叢，40卷1期，頁19-22（2011年）。

1895年〕5月8日以前，在臺灣島及澎湖列島內有一定住所者稱為臺灣住民。⁵³」不問其是否為生蕃（即高山族原住民），皆論為日本帝國臣民。獲得二等獎之時任法院判官的藤井乾助同樣也援引該《臺灣住民身分處理辦法》第1條，但其認為須將該條的指涉對象限於「行政區域內」，由於官吏所做的規定不能對位於行政區域外的對象發生效力，故須先考察蕃人（高山族原住民）所處之地，是否已於清治時期或嗣後為日本帝國編入行政區域內。由於清帝國與日本帝國皆未將蕃人居住地編入普通行政區域內，故無前述《臺灣住民身分處理辦法》的適用餘地，居住在蕃地的蕃人僅屬居住於領土內的（具有法律上人格的）自然人而非國民，惟於日後若經政府的承認，方得被視為日本帝國的臣民。但第一名之從缺，顯示以上這兩種從法規條文所做的法律解釋，皆不能令臺灣總督府滿意。

臺灣總督府對此法律議題所期待的「標準答案」，似乎是由審查委員安井勝次所撰寫的論文來揭曉。安井指出，決定蕃人是否為日本國民之前，須先確定其是否曾為清國國民，因為只有清國國民才該當《馬關條約》第5條所稱之「住民」定義。由於熟蕃（平埔族原住民）於光緒元年〔按：1875年〕便歸由臺灣的地方官管轄〔按：係指將負責理番事務的埔里社廳及卑南廳從過去之為與府同級的理番廳改變為隸屬於臺灣府底下〕，已與一般漢人無異，故將熟蕃認定為清國國民殆無疑義；但就生蕃人，由於其棲息在高山峻嶺而不遵奉法令，清國政府亦將其視為化外之民而放棄，可謂不承認其為國民。而日本領臺後，仍將蕃地置於行政區域之外，可見生蕃人至今仍屬化外之民，惟將來若能服從政令、接受教化，則應再依特別法給予國籍。最後，安井主張自然人未必具有法律上的人格，譬如奴隸即屬不具法律上人格的自然人，畢竟人格係指在法律所承認的範圍內之人格而已；據此，生蕃自古以來常被統治全臺之

53 參見臺灣總督府警務局編，臺灣總督府警察沿革誌第二編：領臺以後の治安狀況（上卷），復刻版，頁653（1995年）。

政權置於法制之外，故生蕃人雖係自然人，但不能謂其具有人格⁵⁴。安井甚至直接表明：「生蕃係化外之民，在我國領土上橫行的野獸而已。」⁵⁵

在前揭「野獸說」的政治氛圍下，臺灣總督府確定了對於高山族原住民族「不適用一般法律」的原則。按絕大部分的蕃地於結束「理蕃五年計畫」的1915年之後，已被納入帝國的有效統治範圍內，因此高山族原住民此後亦被承認為是帝國臣民。然先前「蕃人不適用一般法律」的作法卻仍舊延續，以致於僅有被劃歸到普通行政區當中的一部分高山族原住民〔按：即日治時期所稱的「平地蕃人」，主要為住在花蓮、臺東的阿美族和卑南族〕，始有機會適用與臺灣漢人相同的現代意義法制。於1930年發生霧社事件後，日本統治當局為「加強教化」，擬使高山族原住民族「漸次適用一般法律」，但一直要到二次大戰末期的1945年，方表示將在10年內結束這般不施行法治的特別理蕃行政，惟日本統治者還來不及實現即已因戰敗而離開臺灣了⁵⁶。換言之，雖然高山族原住民在日治時期被視為日本帝國臣民的時間長達30年之久，但明治憲法上所規定之最起碼的形式法治國原則，例如立法事項應由法律或具法律效力之命令加以規範等等，卻極少被施行於高山族原住民。

相對於在臺漢人還有機會在法律生活中接觸到立憲政治的片段，例如從事政治反對運動、辯護士的某些擁護人權活動、法院的高度依法裁判等等，上述高山族原住民族的法律上待遇，使其幾乎無從自日常社會生活中習得立憲制度。不過，即令是在欠缺具體經驗的情況下，某些臺灣漢人在習得日語後，尚且得以藉此探知種種未施行於臺灣、甚至是日本的實證法所拒不採納的西方憲政思想，對於已接受日語教育的高山族原住民而言，是否同樣可能循此途徑

54 參見安井勝次，生蕃人の國法上の地位に就て，臺灣慣習記事，7卷1號，頁1-27（1907年）。

55 參見安井勝次（註54），頁18。

56 就此部分的詳細說明，參見王泰升（註52），頁1-98。

來突破既有法律上待遇的限制，進而產生對西方憲政主義的認識呢？則值得再為進一步的探究。

臺灣總督府自統治之初，便開始基於撫育教化的立場，經由臺灣總督府民政局學務部所管轄的「蕃人公學校」以及由警察所管轄的「蕃童教育所」兩大體系，展開原住民教育事業。蕃人公學校於1922年時，回歸於一般的公學校體系；且自1928年起，蕃童教育所的原住民兒童數開始超過公學校⁵⁷，甚至在1930年代以後，蕃童教育所的就學人數已占原住民學齡人口的6成左右⁵⁸，而成為原住民教育的重點所在。為教化原住民成為天皇制國家下的良順臣民，無論是何種體系的教育均強調「國語」〔按：日語〕與「修身」兩科的學習，後者雖涉及有國家組成的內容，其教學重心終係在於對天皇制國家秩序的服從⁵⁹，再加上蕃童教育所體系的教員係由警察擔任，故不難想見此一教學重心的貫徹程度。是以，一部分高山族原住民確實得以接觸到類同於臺灣漢人的公學校、乃至等同於日本人的小學校等基礎教育內容⁶⁰，且其學童就學比例甚至尚高於漢人學童⁶¹。不過，臺灣漢人約自1910年代起，便逐漸產生以前往日本內地為主的島外留學風氣，其中又以前往接受高等教育的留學者居多，這些留學者在學成返臺之後，往往也成為社會上的菁英⁶²，相較之下，高山族原住民社會似乎沒有相類似的狀況。至於在臺灣接受高等教育者，雖以日本人占大多數，但臺灣漢人亦約占有兩成比例，惟其中就算有高山族原住民，在人數上亦屬極少數⁶³。這樣的

57 參見松田吉郎，台灣原住民と日本語教育，頁62、68（2004年）。

58 參見北村嘉惠，日本植民地下の台湾先住民教育史，頁218（2008年）。

59 關於蕃人公學校的教育內容，以及蕃童教育所的修身教育內容，可參見松田吉郎（註57），頁52-56、153-166。

60 以花岡一郎為例，其便曾就讀於「霧社蕃人公學校」以及「埔里尋常高等小學校」。參見北村嘉惠（註58），頁345。

61 參見E. Patricia Tsurumi著，林正芳譯，日治時期台灣教育史，頁128（1999年），「表13：台灣學齡兒童就讀國民學校比率，1907-1944年，註a」。

62 參見吳文星，日治時期臺灣的社會領導階層，頁104-114（2008年）。

63 臺北帝國大學畢業生中臺灣人與日本人學生的比例約是1：4；臺北高等學校共

結果也意味著日語使用已相當普遍的高山族原住民族，仍難以透過高等教育的途徑來獲悉西方憲政思想。

四、整個日治時期程度有限的初體驗

隨著日本帝國於1930年代之逐漸步向軍國主義，包括前揭的議會請願運動在內的各種社運團體及群眾聚會也逐漸在臺灣社會中銷聲匿跡。而當帝國於1937年進入戰爭狀態後，除了仍給予有限的地方自治團體選舉權，以及戰爭末期為動員臺灣人而擬賦予但終未實現的國政參與權外，其他在明治憲法上所規定的臣民權利保障在事實上皆已落空⁶⁴。因此戰時體制下的臺灣社會，已難以再從實際的法律生活感知明治立憲體制的存在，更遑論理解或支持西方憲政主義相關思想。

綜上所述，姑且不論戰爭狀態對於憲政秩序的限制，日本帝國透過明治憲法所呈現的立憲主義認知，僅流於形式層面的國家統治權須依憲法規定來行使，乃至於國家權力須分立等概念，但對於臣民權利義務的描述重點在於強調天皇對於臣民的體恤，以及臣民對於天皇及國家的效忠，而非對於人民基本權利的保障。隨著日本帝國的領有而來到臺灣的，正是這般對於西方憲政主義有限的理解與採擇。不過，日治下的臺灣社會並未全然接受這些形式主義色彩濃厚的立憲主義觀點，透過各種更為直接的知識追求途徑，部分漢族菁英理解到以人民基本權利保障為核心的他種西方憲政主義，並據以思索臺灣社會所面臨的憲政問題，試圖在明治憲法的既有法律體制內，尋求實踐西方憲政主義的各種可能性，包括主張應設置臺灣

計二十屆的畢業生中，臺灣人僅占22.5%。上述統計中所稱「臺灣人」，似乎沒包含高山族原住民。參見鄭麗玲，帝國大學在殖民地的建立與發展——以臺北帝國大學為中心，國立臺灣師範大學歷史研究所博士論文，頁150-151（2001年）；徐聖凱，日治時期台北高等學校之研究，國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文，頁89（2009年）。

⁶⁴ 參見王泰升，台灣憲法的故事——從「舊日本」與「舊中國」蛻變而成「新台灣」，收於：台灣法的世紀變革，頁286-287（2005年）。

議會。惟只有部分的臺灣人菁英願意且能夠做這樣的嘗試，其終究未能促使一般民眾更加親近西方憲政主義。至於日治下臺灣的高山族原住民族，則不但從實際的法律生活，且從教育的場域，都幾乎被排除於西方憲政主義思想之外。思及此點，則可知一部分臺灣漢人知識菁英之得以和西方憲政主義有所互動，對於臺灣社會而言，已堪稱是一場難能可貴的初體驗，其為西方憲政主義思想所散布的種子，即使為數不多、就算暫時受到戰爭狀態的壓抑，也仍然期待著來日得以再次發芽茁壯。

參、國民黨一黨專制下的憲政主義再體驗

一、以「訓政前置主義」箝制自由民主憲政

第二次世界大戰終於在1945年落幕，其導致臺灣總督府解體，並改由代表同盟國前來接收之國民黨掌控的中國國民政府統治臺灣。被國民黨政權視為中國一省的臺灣，隨即獲得選派制憲國民大會代表的機會，共同參與《中華民國憲法》的制定。相較於戰前日本帝國對於臺灣人菁英追求西方憲政主義的壓抑，國民黨政權從中國內地帶來同樣仿效自近代歐陸法的中華民國法制／法秩序，並從1945年10月25日起施行於臺灣，且即據以讓臺灣人選出參與國政的代表，此似乎意味著許多臺灣人菁英夢寐以求的自由民主憲政生活方式終於有機會實現了。這項歡欣的心情某程度反映了人們在經歷過日治時期1920年代的自由民主實踐活動，以及1935年以降的地方民意代表選舉，業已認知到自由民主是可貴的。

可惜前述滿懷歡欣的期待，換來的卻是刻骨銘心的失望與傷痛。先是在1946年舉行制憲國民大會代表選舉時，發生有多位握有制憲國民大會代表選舉權的臨時省參議員自己聲明參選的情況，結果在應選的17位名額中，竟有8名係當選自臨時省參議員。這樣的

選舉過程與結果，遂引發諸如「正在形成選舉上的空前黑市」、「利用他們自己握有選舉票的特權，都在以此本錢，朋比勾結，以票換票，討價還價，在蔭謀取得國大代表的野望」，以及「真真有包辦之意」等批評⁶⁵。尤有甚者，在1946年11月發生警察為抗拒法院拘提，竟強制囚禁執法人員長達一週的「員林事件」，更是讓約略相當於日治時期臺灣人的所謂「本省人」的菁英份子⁶⁶，經由甫來自中國內地的外省籍官員所呈現的毀法行徑，充分感受到國民黨政權那種連形式上遵從法律都嫌麻煩的統治態度，還真的有別於日本統治當局之已相當遵從形式法治⁶⁷。儘管一部在條文上採取西方憲政主義的《中華民國憲法》已於1947年的1月1日公布，但極為諷刺的是，爆發於同年2月的二二八事件卻使許多成長於戰前日本帝國下的本省人菁英，自此失去得以追求、體驗、甚或是議論西方憲政主義的能力與機會。

65 參見民報社編輯，社論 國大代表的選舉，民報，1946年10月29日2版；永青，民意機關 看了國大選舉 真真有包辦之意，民報，1946年11月2日4版。

66 戰後臺灣被當成中國一省，故不僅日治時期的臺灣人（福佬人、客家人、平埔族人），還包括日治時期的高山族原住民，都具有「臺灣省籍」，且相對於中國其他省份之人而被稱為「本省人」，而居住在臺灣的中國其他省份之人也因此稱為「外省族群」。

67 「員林事件」，或稱「員林血案」，係指臺中縣警察局代理第二科科长許宗喜（外省籍）於1946年11月11日下午，為抗拒臺中地方法院的拘提，而協同轄區警員（外省籍）以武裝手段囚禁前往執行拘捕勤務的多位人員（本省籍）長達一週，期間並造成相關人員重傷、乃至於死亡的情事。儘管這般行政機關公然以暴力行徑侵害司法人員的作為已使輿情嘩然，然而此一事件於公訴後，僅一人因殺人未遂而遭判處有期徒刑5年、褫奪公權3年，其餘被告皆獲判無罪，且妨礙公務部分尚因大赦令而免訴的結果，毋寧更叫人覺得不可思議。關於此一事件的始末，參見蔣時欽，員林血案真相（上），民報，1946年11月21日3版；以及蔣時欽，員林血案真相（中），民報，1946年11月22日3版。至於以「外省人對台灣人之錯誤的優越感」以及「[外省人]法治觀念之缺乏」等省籍與兩者法治觀念的落差等因素來加以評論此一事件，則見蔣時欽，員林血案真相（下），民報，1946年11月23日3版。本案的起訴書參見民報社編輯，員林血案起訴書（上），1947年1月9日3版；民報社編輯，員林血案起訴書（中），民報，1947年1月10日3版；以及民報社編輯，員林血案起訴書（下），民報，1947年1月11日3版；判決書全文參見民報社編輯，員林血案判決書，民報，1947年2月22日3版；以及民報社編輯，員林血案判決書（續），民報，1947年2月23日3版。

隨著國共內戰的白熱化，自1947年12月25日起正式施行的《中華民國憲法》，已有部分條文旋即遭1948年5月10日所公布施行的《動員戡亂時期臨時條款》的凍結。翌年，由國民黨掌控的中華民國政府遷至臺灣，自此確立了一個僅以臺澎金馬作為統治權力實際上所及範圍的「新」中華民國（亦稱「在臺灣的中華民國」）。若從形式上的法律效力而言，直到《動員戡亂時期臨時條款》於1991年5月1日被廢止之後，籠罩在二二八事件陰影下的福佬、客家、平埔族等族群和分別被改稱為「平地山胞」與「山地山胞」的高山族原住民族（以上即本文所稱「本省人族群」），以及自戰後、尤其是1949年跟隨中華民國政府而移居臺灣的外省族群，彼此所共同構成的臺灣共同體，才得以透過該部憲法內的條文，體驗西方憲政主義所期待的自由民主憲政的生活。

在臺灣的中華民國之以凍結憲法條文來作為行憲手段，實沿襲自掌權者蔣中正所熟悉的「訓政前置主義」的想法。其認為在臺灣實施憲政之前，仍應先實行立基於「以黨治國」概念、但在法規範上業已失效的訓政體制⁶⁸，至於其在臺灣所實際延續的訓政體制，則是國民黨政權於1937年至1948年間在中國所曾實施、由最高領導人統領黨部、政府、軍方等三個機構的「戰時訓政體制」⁶⁹。換言之，作為「國家領導人」的蔣中正無論是在戰前的訓政階段，抑或是在戰後號稱行憲的中華民國時期，皆不願受到來自西方憲政主義所要求的「國家統治權須依憲法之規定行使」的拘束。

尤有甚者，1949年年底以後在臺灣社會重新建構的中華民國，

68 關於「以訓政經驗行憲」，已在他處有所論述。參見王泰升（註64），頁294-297；王泰升（註5），頁190。

69 國民黨政權於1928年至1948年在中國所實施的訓政體制，關於論述和運作內容並非一成不變，若就黨部、政府、以及軍方等三個機構於組織形態上所呈現的變遷，則可再細分為五種不同時期的訓政體制，最後一期即是以作為戰時統治機構的國民黨內「國防最高會議」（後來改為「國防最高委員會」）指揮國家機關進行統治事務的「戰時訓政體制」。參見王泰升，國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁128-150（2009年）。

在域內並不存在有足以與蔣中正抗衡的政治勢力，名義上的行憲宣稱更免除了先前名義上尚處訓政時期所承受之應終結訓政的壓力。因此這時所呈現之黨、政、軍大權由蔣中正一人獨攬的「行政權獨大」現象，早已超越西方憲政主義所預設的權力分立框架，反而是趨向期待聖賢出世牧民、從而強調皇帝至高無上權威的傳統中國法政文化。

若從各個人群的屬性與動向來觀察，於戰後臺灣取代原本在臺日本人官僚而居於國家統治階層的國民黨外省政治菁英，在由蔣中正透過國民黨的改造所建構而成的「具行憲外觀的訓政體制」底下，是否將延續其先前在中國訓政時期不遵從憲政主義的既有經驗呢？處於在野位置、熟悉作為新「國語」與「國文」的華語文的外省族群菁英，又是否將根據形式上已施行的憲法典而要求國民黨政府實踐自由民主憲政理念？以下將以1960年的雷震案探究此一問題。另一方面，由於具有日治時期憲政運作經驗的菁英紛紛因二二八事件而死傷或退隱，對於在戰後須接受新的國語文教育、難以繼續用日語吸收西方新知的本省人族群而言，與西方憲政主義的相遇與互動是否須重新再來一次？

二、非常體制下的憲政主義實踐：以雷震案為例

1960年9月4日，正準備籌組「中國民主黨」的雷震，及其於《自由中國》雜誌社的同仁傅正、劉子英，及馬之驩等人，遭臺灣警備總司令部（以下簡稱：「警備總部」）以「涉嫌叛亂」等罪名逮捕。經提起公訴後，軍事法庭於同年10月3日審理此案，並於同月8日做出裁判，雷震遭判處有期徒刑10年，劉子英則遭判處有期徒刑12年，馬之驩判處有期徒刑5年，至於傅正則獲裁定感化3年⁷⁰。全案於同年11月23日進行覆判，唯僅就馬之驩部分改判感化3年，翌年1月10日，國防部以原審於法並無不合為由，拒絕雷震提起非常

70 參見陳世宏等編，雷震案史料彙編——國防部檔案選輯，頁582（2002年）。

訴訟的聲請，全案法律程序自此遂告一段落⁷¹。在此過程中，雖然不乏有來自黨、政、學等各界外省族群菁英對於雷震等人的奧援，甚至連監察院都介入調查，豈料「國家領導人」早已就全案的進行有所裁示⁷²，前揭輿情反應終究只是徒勞無功。

根據目前已公開的政府檔案顯示，在關於雷震等的軍事審判程序中，最引人注目之處莫過於蔣中正曾於宣判當日上午，以總統身分做出：「雷之刑期不得少於十年」、「覆審不能變動初審判決」等指示，而國防部軍法覆判局局長在總統垂詢「有無把握」做到這些指示時，尚且「起立答稱：都可以辦到。⁷³」這般違背當時《軍事審判法》上規定的程序，毋寧更像是帝制中國的皇帝在率領群臣審

71 參見陳世宏等編（註70），頁17-20。

72 從目前收藏於美國史丹福大學胡佛中心檔案館的《蔣中正日記》，可看出蔣中正總統之親自處理雷震案。《蔣中正日記》於1960年（以下同）7月23日的「本星期預定工作項目」即寫：「六、自由中國半月刊雷逆〔按：雷震〕反動挑撥台民與政府惡劣關係，如不速即處置即將噬臍莫及，不能不作最後決心矣。」7月26日寫：「一、雷震逮捕後應警告反動人士者：……」；7月31日的「本月大事預定表」寫：「9. 自由中國半月刊與雷逆問題之解決」；8月27日寫：「一、對自由中國半月刊問題的處理方針：……」；9月7日寫：「主持中央常會……指示乃建雷案主要問題因移轉於劉子英匪諜與雷有重大關係方面，而以其社論叛亂涉嫌為次要因素矣。」9月10日在「提要」中寫：「三、雷案之速結」；9月14日寫：「一、據報美國務院已對我駐美大使館為雷震案作變相警告，可鄙。」9月16日寫：「召見雷案小組商討起訴書要旨」。9月23日寫：「上午入府與岳軍乾三檢討雷案起訴書」；9月24日寫：「上午重核雷案起訴書稿，入府與岳軍鳳翔（乾三）商討修稿與起訴時間」，並在「本星期預定工作課目」載：「6. 雷案決於星期一起訴務期速決」；9月26日寫：「十一時召集辭修冠生昌煥等檢討雷案做最後決定另約正綱來。後下午召集宣傳會談指示起訴後的宣傳計畫與要領并徵詢意見後散會六時由警備總部發布起訴書。因之雷案又進入一個新階段矣。」10月6日寫：「晚召集軍法有關人員 指示其對雷案判決書方針擬立兩種方案候核」；10月8日寫：「審閱雷案判決書甲乙丙三稿，十一時召集辭修岳軍冠生趙琛鳳翔等研討判決書二小時後最後決定用第（乙）種，避免引用意圖顛覆罪之法條而仍處以十年徒刑。」10月12日寫：「下午審核雷案判決書內容」；10月15日在「上星期反省錄」寫：「三、雷案等判決書正文已於星五日正式宣布」；10月18日寫：「對雷案審判不服之抗議問題，特令軍法處加以駁斥之指示」；10月20日寫：「再催覆判局提早結束雷案，最好能在美大選以前結束也」。

73 參見陳世宏等編（註70），頁332。

決重案⁷⁴。從而也透露出戰後統治臺灣的國民黨政權，藉由《動員戡亂時期臨時條款》而在臺灣社會所維繫的「行憲」局面，其實是連戰前日本帝國的形式主義憲政都稱不上的假象。

若再就雷震案的引發契機進行探究，則根據目前已公開的政府檔案顯示，警備總部基於《自由中國》半月刊自第17卷第3期（1957年8月）以來所刊載的種種「敵視本國政府」的「荒謬言論」⁷⁵，至少自1958年9月起，即開始研擬法辦雷震的可行性⁷⁶。在其陳報行政院〈從政治作戰立場對自由中國半月刊荒謬言論之研究報告書〉當中，更是直指雷震等人標榜自由主義、鼓吹成立反對黨等種種言論，「已逾越任何民主國家在抗禦共匪顛覆、保衛國家生存的前提下所預設的言論自由界限」⁷⁷。警備總部的這般陳詞，顯示國民黨統治當局此時已準備將與雷震決裂，而最終是在1960年動手抓人、入他於罪。其實，創刊於1949年11月的《自由中國》豈是直到1957年時才開始標榜自由主義？如果國民黨統治當局所宣稱的「行憲」，得以和雷震等人所標榜的自由主義相安無事長達8年，那麼這個終究到來、似乎無法避免的決裂場面又意味著什麼呢？

相較於同時期的本省人族群以及部分被排除在國家權力運作之外的外省族群，在分別遭遇二二八事件（1947年）、澎湖七一三事件（1949年）⁷⁸，或其他個別的白色恐怖事件後被迫成為沈默大

74 根據當時的《軍事審判法》規定，只有當受判決的當事人不服軍事審判機關長官所核定的判決，從而啟動覆判程序時，總統才須介入核定覆判的內容。參見王泰升，台灣法律史概論，3版，頁220（2009年）。

75 參見陳世宏等編（註70），頁20-25、37。

76 參見陳世宏等編（註70），頁4-12。

77 參見陳世宏等編（註70），頁26-27。

78 發生於1949年7月13日的「山東流亡學校煙台聯合中學匪諜案」冤案，現稱「澎湖七一三事件」，或「山東流亡學生事件」。本案起因於時任澎湖防衛司令的李振清及師長韓鳳儀為擴增澎湖兵員，強行將當時停留在澎湖的煙台聯合中學學生編入部隊，為壓制多數師生的不滿，軍方更以「肅清匪諜」為由大肆逮捕並刑訊師生，最後張敏之、鄒鑑2位校長及劉永祥等5名學生遭冠以匪諜罪名，於1949年12月在臺北馬場町被槍決，至於澎湖當地亦傳有部分學生遭私刑處決，涉案失蹤者更多達200餘人。全案於1997年時始獲平反，並於2008年時

眾，雷震等人尚得透過《自由中國》雜誌，而於1950年代享有國民黨統治當局可容許的「言論自由」，應是由於其屬於反共的自由主義外省族群菁英。出身外省族群菁英的背景不僅決定他們得以作為統治協力者的資格，也奠定其間強韌的人際連繫，這從雷震案發生後所引發的輿情迴響即可見一斑⁷⁹。因而無論其是否佇足於權力核心的周遭，莫不領受了國民黨統治集團所賦予的種種利益（當然也有受到其連累之處，例如來臺灣後失去原有的人際網絡或祖產），以致於標榜自由主義的《自由中國》雜誌所表述的民主理念，仍不免存在著基於族群背景所帶來的侷限性，例如忽視了中央民意代表的不改選、以及其中各省代表的名額及比例與在臺灣的選民結構明顯失衡等等，違反民主原則而對本省人有所不公的問題⁸⁰。也因此，當其本於中國國族認同、較關注外省族群利益的民主化主張，直接槓上統治集團的權力核心時，即難以獲得本省人群眾廣泛的認同與支持。而當這些主張已嚴重威脅而可能動搖權力核心時，更是難以獲得其他仍舊依附於權力核心的外省族群菁英們的支持。於是，這群自由主義外省族群菁英對於西方憲政主義的追求，終究落

在澎湖縣馬公市觀音亭海堤西側興建紀念碑。2011年7月13日，軍方首度面對本案，並由時任國防部副部長的趙世璋代表前往紀念碑處弔祭事件受害者。參見許紹軒，小檔案——七一三事件 台灣第一宗大型白色恐怖案，自由時報，2008年7月12日A8版；劉禹慶、許紹軒，澎湖713事件建碑 地點終敲定，自由時報，2008年7月12日A8版；程嘉文，新聞檔案 山東流亡學生事件，聯合報，2011年7月14日A16版；程嘉文，713事件 62年了 軍方首度承認錯誤 國防部副部長澎湖致祭 強調面對歷史不應迴避與掩蔽 被逮學子憶當日……仍心有餘悸，聯合報，2011年7月14日A16版。出身山東，自述「在1945年5月踏上台灣寶島……我的弟弟和妹妹都是那『八千子弟』〔按：煙台聯合中學學生〕中的一個分子」的作家王鼎鈞認為：「國民政府能在台灣立定腳跟，靠兩件大案殺開一條血路，一件『二二八』事件懾伏了本省人，另一件煙台聯合中學冤案懾伏了外省人，就這個意義來說，兩案可以相提並論。」受到此一見解的影響，後來的報導多有將澎湖七一三事件評價為「外省人的二二八」。參見王鼎鈞，匪諜是怎麼做成的，自由時報，2006年4月12日E6版。

⁷⁹ 於1950年代與1960年代，臺灣的輿論界幾乎都掌握在戰後來自中國大陸、已熟悉華語文的外省族群手中，具有相同背景的雷震等人自然較易得到輿論界的關切。

⁸⁰ 參見王泰升（註5），頁199-200。

得兩頭空的下場。

無論如何，雷震案對自由民主憲政在臺灣的發展，實為一大打擊。對於雷震或同時期熟悉西方憲政主義思想的其他外省人法政學者而言，倘若確實曾因基於外省族群的歷史經驗與集體情感，而或者不忍出言批判、甚或慨然容許國民黨宣稱為了「光復大陸」而為的毀棄憲政秩序的某些行徑，那麼當批判當權者的異議言論開始出現在《自由中國》雜誌時，是否也意味著國民黨政權的某些作為，確已逾越了這群信仰自由主義的外省人菁英所能容忍的極限？或者說，對於1950年代這群離開中國而移居臺灣的自由主義者而言，是否曾經設想過有一種「最低限度憲政」的圖像？對此，《自由中國》雜誌雖曾揭示有積極推動臺灣民主政治的大方向，但隨著雷震案的落幕，不僅是《自由中國》雜誌社的被迫解散，甚至包括案件本身對於其他外省族群菁英所造成的寒蟬效應，已迫使當時殘存無幾的外省族群自由主義者們，就諸如雷震本人於籌組反對黨時所曾提示的族群隔閡或地方主義等更為細緻的問題⁸¹，放棄繼續發表意見的機會。

在持異議的外省族群菁英遭鎮壓之後，繼續主宰臺灣社會思想界的是，自1950年代起即開始在臺灣的校園與社會推行，以中國國族認同、領袖至上、革命民權為內容的黨化教育⁸²。至此，身居臺灣的一般人民，無論其族群別為何，皆少有機會得以接觸到西方憲政主義所揭櫫的自由民主法治的思想。然而西方憲政主義的音符，又豈不會再由另一批人的嘴中、以另一種方式響起嗎？

81 參見薛化元，《自由中國》與民主憲政——1950年代台灣思想史的一個考察，頁148-149（1996年）。

82 參見薛化元、周志宏，百年來台灣教育法制史的考察——以國家權力與教育內部事項為中心，收於：台灣法學會編，台灣法制一百年論文集，頁475-481（1996年）。

三、重行集結的行動者

在歷經1960年的雷震案之後，除了統治者以黨國意識型態片面定義的「憲政思想」外，某些大學內的法政相關科系，成為在臺灣極少數還聽得到西方憲政主義的地方。以1960年代的臺灣大學法律系為例，其教師組成雖以外省族群者居多⁸³，但當中亦不乏有傳承西方憲政主義、或是信奉自由主義思想者⁸⁴。惟基於其歷史經驗與集體情感，再加上雷震案所引發的寒蟬效應，外省族群法政學者所闡述的西方憲政主義思想，或許僅能呈現為其自身所認定的「最低限度憲政」而已⁸⁵。儘管如此，多數為外省人、少數為本省人的戰

⁸³ 參見王泰升，*台大法學教育與台灣社會(1928-2000)*，收於：《台灣法的世紀變革》，頁163、180、203-204、206（2005年）；個別的教師背景則參見頁181-202所示之「表3-2：台大法律系教師背景一覽表」。

⁸⁴ 任教於臺灣大學，曾任法律系系主任、法學院院長、以及教務長的韓忠謨教授即屬一例，其對個人主義、自由主義憲政理念的闡述及主張，參見韓忠謨，*法學緒論*，6版，頁135-140（1977年）。於1972年，臺大校方以《臺大法令》刊登不當的文辭為由，將擔任該刊物社長的法律系學生洪三雄記大過一次、擔任發行人的另一法律系學生陳玲玉記小過一次。在此之前，洪、陳兩人曾遭訓導處申誡，於往見當時法學院院長韓忠謨時，韓忠謨說：「受學校懲戒處分，很多是不名譽的事，……可是，你們被處分的情形完全不同。……你們對於訓導處的這種『懲戒』應該感到是一種『光榮』才對，因為這是一個『苦難』的時代，不必過分計較。」韓忠謨在此表現出對言論自由的肯定，雖然他改變不了國民黨對校園言論的鎮壓。韓忠謨也因為他的自由主義傾向，而無法出任臺大校長。據說韓忠謨因在臺大已經歷系所主任、院長、訓導長與教務長，原已被規劃出任臺大校長，但有人向蔣經國密呈：美麗島事件及黨外政治反對運動，乃至海外從事臺灣獨立運動的許多領導人都是臺大法律系的系友，在臺大法律系執教鞭的韓忠謨應為此負責，豈可被任命為臺大校長，以致政府匆促間指派另一位已退休工學院教授出任校長。參見王泰升（註83），頁214、242。

⁸⁵ 以林紀東教授為例，其雖亦強調國家處境困難，支持行政權優越、國家緊急權的正當性，但仍認為年幼時參加共產黨，因當時尚欠缺責任能力，來臺後縱未自首亦不應論罪，又主張違警罰法係違憲，對於立憲原則猶有一定的堅持。參見劉振強，懷念林紀東先生，收於：《林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集》，頁42-43（2005年）；翁岳生，是經師，更是人師，收於：《林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集》，頁100（2005年）；吳庚，感念 林師紀東，收於：《林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集》，頁114-117（2005年）；賀德芬，巨人的身影，遠去……，收於：《林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集》，頁145-149（2005年）。

後臺灣第一代自由主義法政學者⁸⁶，已在許多受教的本省人、外省人學生心中，播下西方憲政主義思想的種子。

戰後在臺灣受法學教育後至歐陸日本留學、於1960年代中期以後進入法學界的臺灣第二代法學者，改以個人及家族具有日治時期歷史經驗的本省人占多數。前往海外留學的經歷，使第二代法學者得以更為全面地接觸西方憲政主義思想，當中有許多人在返臺後的教學與研究活動中，或較為隱晦地或直接以批判方式，宣揚「增訂版」的自由主義憲政思想⁸⁷。縱令其在學術殿堂中所講述的憲政主義思想，在當時並不足以撼動透過國民教育及報紙廣播等媒體而形塑成社會共識的「國民黨版」憲政觀，卻已讓在臺灣接受其教導或受其影響、為數更多的知識份子，得以掌握西方憲政主義的本意，進而於投身法律實務界或政界之後，援引套用在對於事件或現況的反思與批判。以具有自由主義傾向的第二代法學者及年輕律師為主力，於尚處威權統治的1970年所成立的「中國比較法學會」（1995年改名為現今的「台灣法學會」），即在1980年代扮演國家體制批判者的角色，並於1990年代成為法治正常化的領航者，2000年代繼續守護臺灣的自由民主法治⁸⁸。

不過，促使臺灣社會重新認識西方憲政主義的契機，主要仍是來自於政治環境的轉變。當中華人民共和國政府於1971年取代了中華民國政府於聯合國內的「中國」席位，使得在臺灣向來本於中國

86 在戰後臺灣第一代自由主義法政學者中，屬外省族群者有如薩孟武、殷海光等，屬本省人族群者則如彭明敏、劉慶瑞。關於臺灣各個世代法學者的認定及其學說內涵，參見王泰升，四個世代形塑而成的戰後台灣法學，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1367-1428（2011年）。

87 以任教於臺大法律系的憲法、行政法跟刑法學者為例，諸如蔡墩銘於1965年、翁岳生於1966年、蘇俊雄於1970年、廖義男於1973年、李鴻禧於1974年返臺任教，其皆曾致力於宣揚當代西方憲政主義理念。相對於多數採取隱晦式的批判，李鴻禧較直接地以自由主義立場批判當時憲政體制。參見王泰升（註83），頁164、190-191、193-195。此外，專攻行政法學的城仲模係於1971年返臺，後來長期在中興大學法商學院（今臺北大學）法律系任教。

88 參見王泰升、曾文亮，台灣法學會四十年史，頁21-24、132、233-237（2011年）。

國族認同，以「中國政府」自居、合理化其少數族群統治的國民黨政府⁸⁹，不得不提供本省人族群更多參與政治的機會，以維持其統治正當性。經由1972年對動員戡亂時期臨時條款的修正，國民黨政府有限度的開放中央民意機關增額代表的定期改選（包括國民大會代表、立法委員，以及監察委員）。這些持續進行、且以臺灣作為一個政治單元的中央民代定期改選，不僅為以本省人族群為主的反國民黨政治菁英們提供一個全臺串連的機會，且讓同樣生活在臺灣的本省人與外省人逐漸產生「共同感」，開始醞釀日後澎湃的「臺灣（共同體）意識」。在當時被稱為「法律假期」的選舉活動期間，反國民黨的政治菁英即以在一般學校的教室聽不到、在一般報紙上看不到的自由民主憲政理念，嚴詞批判國民黨的作為，讓西方憲政主義思想一點一滴、或明或暗地傳送到臺灣社會上一般民眾的心裡。

開放增額民意代表的定期改選或許對於國民黨政府的統治、對於反國民黨勢力的茁壯，甚至是對臺灣社會落實自由民主憲政一事都帶來了助益，卻仍無法停止在臺灣的中華民國日趨嚴峻的國際外交頹勢。1978年12月美國宣布將自翌年1月起與中華人民共和國建交，並於一年後終止與中華民國於1954年所簽訂的共同防禦條約。面對此一外交衝擊，時任總統的蔣經國隨即發布緊急命令，延緩正在進行的增額民意代表選舉，停止一切競選活動⁹⁰。在正式的參政途徑受阻的情況下，當時由反國民黨的政治人物所組成，而被稱為「黨外」的政治團體⁹¹，乃積極發展群眾運動，並於1978年12月25日

89 參見吳乃德，台灣族群政治理論的初探，收於：張茂桂等著，族群關係與國家認同，頁32（1993年）。

90 參見行政院研究發展考核委員會編，美麗島事件檔案導引，頁4（2003年）；黃富三編，臺灣地區戒嚴時期政治案件——五〇～七〇年代文獻專輯——美麗島事件，頁21-22（2001年）。

91 為因應1978年年底的中央民意代表增額補選，非屬國民黨的政治菁英為擴大參政機會，曾於10月組成「臺灣黨外人士助選團」，由康寧祥擔任主席，黃信介、余登發為總聯絡人，施明德為總幹事，預備於全台各地進行的助選活動。

共同發表〈黨外人士國是聲明〉，其中除申明「堅決擁護民主憲政，反對暴力、熱愛和平」的基本立場外，尚且提出諸如：全面改選中央民意代表、實施地方自治、確立司法獨立、軍隊國家化、確保學術獨立及言論自由、解除戒嚴令，以及人身自由保障等奠基於西方憲政主義的主張⁹²。此後，黨外人士與國民黨統治當局之間基於言論自由與政治參與而起的衝突不斷，雙方對立的局勢也日趨緊張。於1979年12月10日，由黨外人士創辦的《美麗島》雜誌社不顧當局的禁止，於高雄舉行世界人權紀念大會，最後引發群眾與情治單位之間的大規模衝突，此即「美麗島事件」，或稱「高雄事件」⁹³。事後，《美麗島》雜誌社遭警備總部查封，國民黨政府更大舉逮捕與事件相關的眾多黨外人士，並以唯一死刑的叛亂罪起訴為首的黃信介等8人。在國際特赦組織(Amnesty International, AI)的關切下，美麗島事件的軍事審判程序於1980年的3月公開舉行，在為期1個月的審理期間，被告與辯護律師團皆能暢言其政治理念與法律見解。最後軍事法庭於4月18日作成判決，其中雖無人被判處死刑，卻皆為12年以上有期徒刑至無期徒刑不等的重刑；同年5月30日，全案最後由國防部所組成的高等覆判庭覆判定讞⁹⁴。

國民黨政權藉由美麗島事件的審判削弱了反對勢力，但公開的審判過程及媒體的大幅報導，卻使得軍事檢察官與涉案被告及辯護律師團之間的對話傳播至法庭外，其情景猶如1920年代從事議會請願運動者之藉由法庭向公眾傳達政治理念。於是更多的臺灣民眾，對西方憲政主義思想在政治生活上的實踐，有了較為清晰的認識與想像，且將其支持的態度表現於緊接而來的幾次選舉上。原先僅存

參見行政院研究發展考核委員會編（註90），頁4。

92 參見李筱峯，台灣民主運動40年，頁136-137（1991年）。

93 參見王泰升、薛化元、黃世杰編著（註9），頁158。

94 其中黃信介處有期徒刑14年、褫奪公權10年；施明德處無期徒刑、褫奪公權終身；姚嘉文、張俊宏、林義雄、林弘宣、呂秀蓮、陳菊等6人皆處有期徒刑12年、褫奪公權10年。關於美麗島事件的審理過程及判決結果，參見黃富三編（註90），頁47-48。

在於學術殿堂內的自由民主憲政思想，也隨著在法院內相關訴訟的進行，成為與國家實證法具體結合的法律上主張⁹⁵，並促使制度上扮演擁護人權角色的律師成為推動自由民主憲政的一股力量。

當「民主進步黨」（以下簡稱「民進黨」）在解嚴前的1986年宣告成立，並投入增額中央民意代表選舉時，民主化的浪潮已非國民黨政權所能遏止。另一方面，已與地方派系建立侍從恩庇關係、又納入許多本省人政治菁英的國民黨，此時業已具有透過民主選舉來延續政權的能力了。按1987年7月的解嚴決定容有受到在野政團及美國政府的壓力，但也透露出國民黨政權對於各項選舉的勝選自信；孰料作為國民黨外省政治菁英領導人的蔣經國在宣告解嚴的半年後即離世，且引發國民黨內部的權力鬥爭。最後接下蔣經國位置者是國民黨內屬於本省人政治菁英的李登輝，其雖仍舊身兼政黨、政府、和軍隊的最高領導者，但李登輝運用國民黨「黨國體制」所欲推動的改革方向，卻是民主憲政體制下的政黨政治，而不再是源自中國訓政經驗的一黨專制⁹⁶。

95 當然，大學憲法課程所講授的自由民主憲政知識，並非僅間接地透過法律實務的運作而與臺灣社會發生互動，譬如任教於臺灣大學法律系的李鴻禧教授，便自1980年代起，或是透過撰寫報章社論、或是透過政見發表會的助講場合中，以生活口語的方式，向多數未曾接觸過法律專業知識的社會大眾，傳遞其所主張的自由民主憲政思想。參見王泰升、曾文亮訪問，台灣法律人的故事，頁75-81（2011年）。

96 李登輝擔任國民黨黨主席期間的政治上作為，基本上仍是為了延續國民黨在臺灣的統治地位，但亦有論者從2000年國民黨的挫敗，認為「事後看來，李登輝等於在執行一個毀滅國民黨的政治策略」，參見朱雲漢，國民黨與台灣的民主轉型，二十一世紀雙月刊，65期，頁11（2001年）。雖然不同立場者會有不同的評價，但李登輝確實調整了國民黨政權的發展方向。

肆、政黨輪替下的憲政主義新體驗

一、自由民主憲政的實現及人民憲政觀的轉變

曾留學美國、具有臺灣主體意識的李登輝，於1990年3月確立其在「黨國體制」內的控制實力後，便開始回應長期以來存在於社會上的憲政改革訴求⁹⁷。例如在1991年5月1日起終止《動員戡亂時期臨時條款》，同時為使中華民國憲法得以接軌至臺灣社會當時的政治現況，更六度進行修憲，逐次完成《中華民國憲法增修條文》。根據增修條文的內容，首先開放中央民意機關代表的全面改選，其中包括1991年的國民大會代表全面改選、1992年的立法委員全面改選。再者，監察委員在經1992年修憲後已不再由民選產生。中央民意機關從此可回歸其在憲政架構中應有的位置，由於民代須定期受選民檢視，自不再如過去之依訓政經驗全然聽從黨部指揮⁹⁸。2000年的修憲更限縮了國民大會職權，使國民大會成為任務取向的非常設機關，將為人詬病的三頭馬車式中央民意機關，改造為實質上「單一國會」⁹⁹。尤要者，自1996年起，總統選舉也改由全民直選，每屆任期4年，並得連任1次。這樣的修改不僅使李登輝成為第一位由臺灣人民直選的總統，甚至催生了2000年的政黨輪替以及2008年的二次政黨輪替。

由於《中華民國憲法》的本文原即參照戰後西方的憲政主義而制定，故「回歸憲法」，亦即排除《戒嚴令》與《動員戡亂時期臨時條款》等等加諸於憲法本文的束縛，自然成為臺灣人民實現自由民主憲政的一條捷徑。是以在李登輝著手排除這些束縛之後，即僅

97 就時間點來看，1990年3月由大專學生所自主發起的「三月學運」，堪稱是與李登輝的改革最為接近的一次社會運動，然而其所訴求的憲政改革事項，毋寧是傳承或分享1970年代末期以來黨外運動所持續主張的改革內容。

98 不過，擁有龐大黨產的國民黨黨中央，仍可藉提供選舉所需的經費，來拘束其黨籍民代。

99 參見林紀東，中華民國憲法釋論，55版，頁466-469（1992年）；王泰升（註74），頁141-142。

需就政府組織、以及權力分立架構這類必須與時俱進的部分進行調整即可。因此在上述的修憲內容中，除了選舉所必然涉及的選舉權以外，少有其他涉及基本人權方面的內涵。然而，雖《中華民國憲法》對人權保障的規定「堪稱完善與先進」¹⁰⁰，但倘若沒有憲法解釋機關的積極任事，這些言簡意賅的人權保障規定恐怕也難具體地落實於臺灣社會。所幸司法院大法官會議於1990年代以後，已作成許多有助於保障基本人權的解釋。例如，關於人身自由方面有司法院釋字第384號、第392號，以及第436號解釋¹⁰¹；在講學自由部分，有司法院釋字第380號及第450號解釋¹⁰²；就言論自由部分，則是司法院釋字第364號及第407號解釋¹⁰³；至於司法院釋字第455號解釋係涉及集會自由¹⁰⁴；司法院釋字第443號解釋則論及限制自由的要件¹⁰⁵。固然大法官解釋亦不乏對限制人民自由之法律規定予以容忍者¹⁰⁶，但整體而言，這些解釋已移除了國家權威加諸學生、軍人、甚或是一般人民的重重束縛，使人民得以成為國家真正的主人。立法機關對於落實人民基本自由權利之保障，同樣扮演著重要的角色。例如1992年修正《中華民國刑法》的內亂罪規定，將僅存於言論層次者除罪化，或是1999年對於《出版法》的廢止，以及對

100 見許宗力，基本權利——第一講 基本權利的起源與發展，月旦法學教室，試刊號，頁89（2002年）。

101 司法院釋字第384號解釋認為檢肅流氓程序有違人權；司法院釋字第392號解釋則指出檢察官於刑事訴訟程序上應無羈押權；司法院釋字第436號解釋則闡明軍人在平時於一定條件下得就軍事審判機關終審判決向普通法院請求救濟。

102 司法院釋字第380號解釋認為教育部未經大學法授權自不得為有關大學共同必修科目的規定；司法院釋字第450號解釋則認為《大學法》中應設軍訓室之強制規定因不符大學自治之旨而違憲。

103 司法院釋字第364號解釋揭示人民有平等接近使用傳播媒體之權利；司法院釋字第407號解釋認為猥褻出版品的認定應本言論自由之旨而兼顧公序良俗。

104 司法院釋字第445號解釋強調集會自由為實施民主政治最重要的基本人權，故人民對集會內容有表達自由、法律上有關許可集會的要件亦須具體明確。

105 對於未經法律明確授權之限制自由的規定，司法院釋字第443號解釋係否定其效力。

106 參見葉俊榮，從國家發展與憲法變遷論大法官的釋憲機能——一九四九至一九九八，臺大法學論叢，28卷2期，頁16-17、26-29（1999年）。

於政治結社和集會遊行之管制密度的降低。

上述法制或憲法解釋上的演進，實由來於下述的三股政治勢力，都策略性地使用「自由民主憲政」概念追求己方的政治利益，故連帶的使臺灣社會一般人對西方憲政主義制度有更多接觸機會，且擁有更多新的體驗。按在黨外運動崛起的1980年代時，反國民黨的本省人政治菁英為了爭取更多的政治參與機會，即訴諸西方憲政主義中的自由民主，來引起同樣在政治等場域遭遇或感受到不公待遇的本省人一般民眾的共鳴。而這個年代的本省人族群，也的確較之前敢於表現其認同臺灣及臺灣文化的傾向，較重視諸如保障人身自由、言論自由、更多政治參與、政治權力的分享，以及提高本省人族群在政治及社會上地位等議題¹⁰⁷。以本省人政治菁英為主的民進黨成立後，為了突破國民黨政權在教育體系和傳播媒體層面的封鎖，持續透過集會演講或遊行等與民眾直接接觸的方式，向本省人選民推銷西方憲政主義底下自由民主的理念，並以《中華民國憲法》中的基本自由權利觀念合理化其政治反對的立場，進而也吸引了某些信仰自由主義的外省人知識份子的支持¹⁰⁸。

於1990年代，隨著李登輝主政下的憲政改革，原先在政治上掌握絕對性支配地位的國民黨外省政治菁英們，已不能不與黨內本省人政治菁英分享權力，故開始積極參與立憲政治的實踐，亦即中央民意代表或地方行政首長的選舉。來臺後即總是與國民黨政權保持利益連繫的外省族群，在選舉時可能就基於少數族群危機感而支持這群國民黨外省政治菁英。然而，為爭取為數更多的本省人選民，這些在過去數十年一直反對自由主義或民主憲政的國民黨外省政治

¹⁰⁷ 參見田弘茂著，李晴暉、丁連財譯，大轉型——中華民國的政治和社會變遷，頁58（1989年）。不過，在臺灣總人口中占大多數的本省族群的內部一致性，遠比不上人數相對較少的外省族群。已有許多屬本省族群者，在接受國民黨主導的教育之後，亦傾向認同「中國」、支持國民黨及政府、強調安定。這也使得外省族群在臺灣，不致於成為絕對不變的少數。

¹⁰⁸ 參見王泰升（註64），頁318-319。

菁英¹⁰⁹，善用其長期以來在傳播媒體及文教市場上所佔優勢，營造社會形象及聲望以爭取選票¹¹⁰，並援用帶有「自由民主憲政」意涵的各種論述，批判主要由國民黨內本省人政治菁英所組成之李登輝所領導的國家權威或執政集團。

迨2000年首次政黨輪替，成為在野黨的國民黨內部本省和外省政治菁英攜手合作，大肆運用著「自由民主」的修辭來對抗取得中央執政權力的民進黨政府。於是，朝野政治人物無不將諸如「自由民主」或「人權保障」等說詞掛在嘴上，但其對於西方憲政主義的認知與堅持的程度，恐仍是未知數。

二、國家真實與法制上宣稱矛盾以及相異的國族認同

當李登輝經臺灣人民投票而當選為在臺灣的中華民國第一位民選總統時，民主選舉已完整地成為臺灣共同體憲政秩序的一部分了，但其在1990年代為媒合《中華民國憲法》與臺灣共同體而為的修憲工程，仍未解決因《中華民國憲法》宣稱之領土異於事實上國家主權所及範圍，所引發的「中華民國法制虛構化」問題¹¹¹。在

¹⁰⁹ 按自由主義的基本立場是反對「國家」介入一般人民社會生活，故當這些政治人物本身就等於是「國家」時，自然傾向於壓制自由主義，而一旦「國家」等於其敵對的政治勢力時，即反過來支持自由主義，也是可以理解的。就此，可檢證幾位指標性人物，在整個政治生涯所發表的言論主張或具體行動，是否前後一貫地支持自由民主立憲思想。

¹¹⁰ 關於傳媒與文教在臺灣法律史上討論，參見王泰升（註74），頁122-123、175-176、189。不過，以華語文為主的傳播媒體及文教界，對於平常講臺灣福佬話、客家話的民眾影響力較有限，故國民黨外省政治菁英為爭取彼等的選票而開始勤學臺灣福佬話、客家話，以在各種選舉的場合中使用這些語言，但通常在選舉落幕後其又回到佔優勢的傳媒及文教界，延續那種以華語為尊、其他在地語言為卑的文化氛圍。

¹¹¹ 在臺灣，雖然有許多法學者傾向於認為1991年的《中華民國憲法增修條文》，已默示地改變憲法上對人民及領土的範圍，使領土不再及於中國大陸，但持不同意見者亦不在少數。由於作為中華民國法之有權解釋機關的司法院大法官會議，一直不願對此議題表態，故在未明確改變蔣中正總統執政以來國家機關所宣示的「領土及於中國大陸」之前，中華民國法規範體制本身仍是維持著此一見解，從而也構成了在此所描述的「虛構化」現象。參見李建良，人民與國家「身分連結」的法制詮要與法理探索——兼論臺灣人國籍的起承

1990年代的增修條文中，僅將國民的資格（以享受權利負擔義務）賦予居住在「臺灣地區」的人們，以解決國家占多數的政治資源竟由在實際人口上屬少數的外省族群享有的不合理現象。當時為了要維持法制上的領土宣稱，尚於增修條文中規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」（第11條），並據此公布施行《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，且根據其第2條規定可將「大陸地區」解釋為「政府統治權所不及之領土」¹¹²，以滿足《中華民國憲法》上領土包括中國大陸的規範上宣稱。總之，李登輝執政時，雖然在實際運作上已盡量將臺灣共同體當成一個國家，但在中華民國法制／法秩序上，臺灣仍僅是個「地區」。

在終結國民黨對臺灣長達55年的統治後，由陳水扁擔任總統的民進黨執政時期（2000-2008），對於前揭具有虛構性質的中華民國國家法制¹¹³，又採取什麼樣的立場與作為呢？在民進黨1995年3月定案的〈基本綱領——我們的基本主張〉（即現有〈民主進步黨黨綱〉的第一部分）中，仍保留其於1991年10月所增列的「建立主權獨立自主的台灣共和國」項目，並在第1款中主張：「依照台灣主權現實獨立建國，制定新憲，使法政體系符合台灣社會現實」¹¹⁴。不過，當民進黨於1999年5月修正其〈行動綱領——我們對當前問題的具體主張〉（即現有〈民主進步黨黨綱〉第二部分）時，不再提

斷續問題，臺大法學論叢，36卷4期，頁22-25（2007年）。

112 公法學者李建良主張，統治權不及之地區（未領之土），自難以領土稱之，因此《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》將大陸地區視為我國領土一部分的條款僅具有宣示作用，而無任何法律上的意義。參見李建良（註111），頁27-28。筆者雖贊同李建良對於此條款的法律解釋，惟此尚非中華民國實證法秩序的見解，在臺灣有些法院仍根據《兩岸關係條例》而認定大陸地區為我國領土的一部分。

113 在此所謂的法制的虛構，係相對於政治現實上根本不存在有一個同時領有中國大陸與臺灣的國家或政府而論。

114 參見民主進步黨，民主進步黨黨章·黨綱，頁14-15。資料來源：民主進步黨網站，<http://www.dpp.org.tw/history.php>（最後瀏覽日：2012年3月19日）。

及「制定新憲」¹¹⁵，且在增訂的〈台灣前途決議文〉（即現有〈民主進步黨黨綱〉的第三部分）中改稱：「台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，……。台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。¹¹⁶」就此而論，當時的民進黨毋寧是支持前述李登輝採行的路線。迨民進黨籍的陳水扁當選總統開始執政之後，民進黨僅在執政晚期的2007年9月時，於〈民主進步黨黨綱〉新增第六部分〈正常國家決議文〉中，提出「早日完成台灣正名，制定新憲法」的主張¹¹⁷。

可見陳水扁在其8年的總統任內，於大多數的時間裡，依舊迴避國家法規範上臺灣還是「地區」的現狀；僅在陷入弊案風波，以致對於確立臺灣法理上獨立等改革運動，已失去領導者所需之無私的道德光環與高度時，才提出制憲之議，又怎麼可能凝聚國民意志，解決李登輝所留下的國家法上領土虛構化問題呢¹¹⁸？民進黨政府之閃避臺灣在法理上尚非獨立國家的問題，所造成的結果之一是，沒機會向臺灣人民說明：此一問題涉及複雜的國際因素，故應先求內部具有共識，方能對外爭取。在「未來應有的目標」與「當下現實的條件」兩者未被明白區隔底下，不妥適的法規範現狀不僅未遭到徹底的批判，反而被持續了。

於是，帶領國民黨重返執政的馬英九，即在2008年5月20日就職後，重拾蔣中正與蔣經國父子執政時期所宣稱、中華民國法制所虛構的：臺灣是一個「以中國大陸及臺灣為領土的國家」底下的

¹¹⁵ 參見民主進步黨（註114），頁23-29。

¹¹⁶ 參見民主進步黨（註114），頁31。

¹¹⁷ 參見民主進步黨（註114），頁44。

¹¹⁸ 當然，中國持續以武力威脅臺灣不得從事修憲或制憲等法規範上的改變，也是造成民進黨政府對於制定新憲這般欠缺積極作為的原因之一。較詳細的論述，請參見王泰升，中華民國法體制的台灣化，收於：台灣法的斷裂與連續，頁186-187（2002年）。

「地區」。按當今國際社會所公認的中國，早已是中華人民共和國，而非位於臺灣的中華民國。且若其欲堅持此一虛構的中華民國憲法秩序的話，則中華民國政府乃是一國之「中央政府」，相對的中華人民共和國政府係屬《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》中所稱的「大陸地區政府」，僅具中華民國法規範上的地方政府性質。然而，同樣在這一部憲法底下擔任總統的馬英九，卻無法展現蔣氏父子對於自身為中央政府的堅持，反而願意在「一個中國」的召喚下降格為「臺灣地區」政府。例如，身為前揭「中央政府」元首的馬英九，竟以「擱置主權爭議」為由，認為其與中華人民共和國政府委派的代表會面時，不須堅持用國家元首身份出現¹¹⁹。而這般「擱置主權爭議」的結果，卻造成中國在國際社會上一再宣示其對臺灣之「主權」。當然，馬英九在公開的談話中，並不承認名稱為「中華民國」的臺灣的國家資格(statehood)，已一再地在國際法或內國法上遭受侵蝕。

欲解析上述兩蔣、李扁、馬政府等，對於「中華民國法制虛構化」問題所採取的不同立場，需理解臺灣共同體自身隨著自由民主憲政思想的漸次蓬勃，而形成一種新的國族認同(national identity)，並已足以和法制上所宣稱的論述相競逐。從1945年統治當局的更替，一直到1988年政治強人蔣經國的逝世，在這長達44年欠缺自由民主的年代裡，臺灣的執政當局一直鼓吹「中國國族主義」，亦即住在臺灣的人們必須與住在中國大陸的人們作為一個「族」(群體)並建立一個國家，這個政治性群體即是具有「中國國族」意涵的所謂「中華民族」，為了捍衛這個現實上不存在的「想像」，執政當局甚至透過國家刑法中處罰最嚴厲的內亂罪，來制裁任何反對這項意識型態的臺灣住民。然而，從西方憲政主義的觀點而論，人民為了追求共同的利益而組成國家，並要求國家須遵守人民基於該項

119 在中國海協會會長陳雲林來臺商談兩岸協議之前，馬英九總統表示臺海兩岸政府領導人可互稱「先生」，藉此擱置主權爭議。參見蕭旭岑、陳洛薇，馬：陳雲林來就稱呼我馬先生，中國時報，2008年6月18日A2版。

利益所協商議決的內容，此即憲法上的規定，是以國家在行使統治權時，自不可侵犯人民所保留的自由權利¹²⁰；亦即，人民先於國家而存在，是由人民決定自己需要什麼樣的國家。據此觀點，當然可僅僅以住在臺灣的人們來作為一個「族」（群體）並建立一個國家，而這就是「臺灣國族主義」的內涵。換言之，臺灣國族主義的產生條件，勢必關乎在臺灣的漢人及原住民超越了固有文化中的政治哲理，轉而接受來自西方的自由民主憲政觀念等因素，也因此當臺灣伴隨著1990年代起自由主義憲政思想的漸趨興盛及不斷的實踐，在言論市場上自然會出現臺灣國族主義的主張。

然而，中國國族主義早就在臺灣的憲政架構中佔到有利且有力的位置。於1946年為了一個包括臺灣與中國大陸（後來在規範上宣稱包含外蒙古）在內的中國國族想像而制定的《中華民國憲法》，被1949年12月9日在臺灣重新開張的政府，拿來當作在臺灣社會所建立之國家的憲法，當時臺灣社會的人們在蔣中正所率領的威權專制政府軍警特的監視及武力威脅下，不能也無從對是否接受這般「繼受舊中國憲法」表達意見。若從國家實證法及政治實踐而言，具有制憲與修憲職權的國民大會代表，一直要到1991年才由所有的臺灣人民選舉產生，臺灣人民自此才有機會表達其是否採納這部中華民國憲法之意願。換言之，由於參與制定《憲法增修條文》的國大代表係於1991年時，由所有臺灣人民所共同選出，因此若要將《憲法增修條文》的制定解釋為臺灣人民已接受《中華民國憲法》的本文¹²¹，固無不可，但這同時也等於承認臺灣人民在將來可廢除這部憲法。不過，如前所述，由於《中華民國憲法》內的基本人權

120 依自然法學說，人類天生享有生命、自由、財產等天賦的自然權，為了確保這些權利，人類才結成國家，其天賦的自然權利才因而被編纂為實證法，形成憲法的內容。參見李鴻禧（註3），頁8。

121 正因為可將此解釋為臺灣人民對憲法內涵的意見表達，故如前揭註111所示，有許多法學者據以認為《憲法增修條文》已默示地改變憲法上對人民及領土的範圍，而使領土不再及於中國大陸。

規定，以及藉其所做出的大法官解釋，皆有助於臺灣人民享有自由民主憲政生活，因此一般民眾在「一動不如一靜」的惰性下，尚不覺得有廢除該部憲法的迫切需要，導致那些有關中國國族想像的規定繼續存在。再者，國民黨外省政治菁英過去就是以這些具中國國族想像的規定為名，行少數族群統治之實（形式上由其代表中國多數省份），由於其在1990年代以後，仍在傳播媒體及文教事業上擁有足夠的優勢，並藉以強力維繫對其有利之憲法上關於中國國族主義的宣稱。此所以在李登輝和陳水扁主政時都不太能將中國國族主義與臺灣國族主義的競逐議題化，更遑論是要嘗試改變這些既存的憲法規定。

更值得注意的是，在臺灣外部的中國政府，為阻止臺灣人民走向其所稱的「法理臺獨」，竟以「非和平方式」威脅臺灣人民不得修改這些具有中國國族主義想像的憲法規定¹²²，並持續企圖使其成為在臺灣的中國國族主義者所可能結盟的對象。問題是，共處於臺灣自由民主憲政秩序下的臺灣人民，可以因為國族認同之故而與意圖消滅此自由民主憲政秩序的國家合作嗎？或許關鍵因素在於，對共同生活在臺灣的人民而言，究竟自由民主憲政與中國國族認同何者優先呢？

三、觀念分歧的行動者

國民黨一直是主導戰後臺灣憲政發展的要角。國民黨於2000年失去執政權後李登輝被迫下台去黨，繼任黨主席且比較屬於本省政治菁英的連戰於2004年再因總統選舉敗北而失勢，於是以馬英九為

¹²² 依中國《反分裂國家法》第8條之條文，只要「以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」，中國即「得採取非和平方式及其他必要措施」。換言之，臺灣人民如果拒絕與中國合併，中國即考慮訴諸武力侵略。關於中國這項立法的討論，可參見台北律師公會編，律師雜誌，309期（2005年），所刊之數篇文章。

首、具有黨國威權統治經驗的外省政治菁英重新掌握了國民黨內權力核心，並與同樣失去權位的該黨本省人政治菁英合力對抗民進黨。歷經權力結構更新的國民黨在2000年退居在野之後，即運用其在立法院仍占多數的優勢，並以「自由民主」為名對抗國家行政權。但有別於1990年代之前黨外或民進黨所對抗的是一個欠缺民主正當性的國家，此時他們所對抗的是一個經民主憲政程序所選出的政府，卻時常執意以杯葛手段讓國政空轉。這般政治困局的產生，固然亦可歸因於憲法上對「朝小野大」所致行政與立法兩部門陷入僵局時，欠缺妥當的解套措施，但無法基於共同的國家利益而形成相互協商、尋求共識的憲政文化，在立法部門擁有優勢的國民黨與享有中央行政部門執政權力的民進黨一樣難辭其咎。其中，2004年總統選舉敗選後的種種作為，特別顯現出在野時期國民黨的欠缺民主憲政素養：先是任意上街頭擾亂社會秩序，並在立法院推動後來被認定一部分違憲的真調會，最後甚至在司法機關付出高額成本後做出裁決了，仍不願「服輸」¹²³。終於，時任總統的陳水扁涉嫌貪瀆一事，讓國民黨獲得攻擊民進黨政府的絕佳使力點，包括支持在街頭上的「紅衫軍」抗爭。

前述民進黨執政時期的國政空轉或停滯，以及國民黨支持者運用其在傳播媒體界的優勢，而對民進黨政務官¹²⁴、陳水扁家族或親

123 在2004年總統大選前一天的3月19日，民進黨籍總統及副總統候選人陳水扁及呂秀蓮，遭人持土製手槍射擊，分別造成陳水扁的腹部與呂秀蓮的足部擦傷。次日，陳、呂以些微過半的選票勝出，但連、宋陣營拒絕承認敗選，認為槍擊事件係為陳水扁所自導自演，從而發動為期一週、引起警民衝突的民眾集會。爾後更利用其在立法院的優勢通過《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》，惟該條例被司法院釋字第585號解釋認為部分違憲，以致此特別委員會實際上並未運作。此外，連、宋亦向法院提起「陳、呂當選無效」及「該次選舉無效」兩項訴訟，經動員進行全國性驗票後，結果陳、呂票數仍稍高於連、宋；第一審的高等法院均已駁回這兩項訴訟，於2005年6月17日，最終審的最高法院已就陳、呂當選無效之訴，判決連宋敗訴確定，但國、親兩黨仍批評司法不公。參見《自由時報》於2005年6月18日A4版的相關報導。

124 例如2001年一肩擔起「南科高鐵減震」計畫的當時國科會副主委謝清志，於

信涉嫌貪瀆進行「媒體審判」¹²⁵，使得許多臺灣民眾對民進黨政府相當不滿，甚至導致國民黨過去以黨庫通國庫等集團式「貪瀆」所得的鉅額黨產，因扁案而不再被責難，竟還得以自稱「清廉」¹²⁶。

2006年在媒體將減震工程案描述為「官商勾結」的貪污案件之後，檢察官似乎即以「看報辦案」心態展開偵辦動作，以致謝清志被收押、再被以「圖利」罪起訴。2008年7月間臺南地方法院判決謝清志等10位被告均無罪，同年10月間，南科高鐵減震工程完工，證明已成功地解決問題。其後檢察官對謝清志及承包商提起第二審上訴，但遭臺灣高等法院臺南分院駁回。檢察官再為第三審上訴，2011年7月間最高法院將該案發回更審，故於今仍處於高等法院審理階段。但無論如何，本案業經第一、二審法院宣告無罪，然而2006年12月26日《中國時報》的標題寫著：「起訴六教授／學術蠹蟲又一樁」，《聯合報》更以「檢：精心設計的官商勾結案」為標題，卻已在當時一定程度形塑出「民進黨高官貪污」的社會印象。關於本案經過，當事人謝清志曾出書詳細交代始末，參見謝清志、彭琳淞，謝清志的生命振動，頁150-152、169、175、270-273、359-368（2008年）。

125 在法律上是否構成貪瀆罪應由法院認定，而非由媒體來審問定罪。2006年11月今特偵組的前身臺灣高等法院檢察署查黑中心檢察官，以總統夫人吳淑珍等涉嫌不實核銷國務機要費，挪為私人支出，觸犯共同貪污及偽造文書罪為由提起公訴，並認為現任總統陳水扁係涉嫌該兩罪之「未經起訴之共同正犯」，將俟其經罷免或解職後再行訴究。陳水扁卸任後的2008年11月11日，特偵組以扁珍兩人涉嫌在國務機要費、竹科龍潭基地及安亞專案機密外交等案中獲鉅額不法取得，並將款項匯往海外，涉及貪污、洗錢等罪，向法院聲請羈押禁見，隔日法院准予羈押，同年12月12日特偵組正式起訴前總統陳水扁。惟法院審理卸任總統的某些不合程序正義的作為，例如更換曾對被告為有利裁定之法官，使本案蒙上「政治追殺」的陰影。2010年11月最高法院就龍潭案、陳敏薰涉買官案分別判處陳水扁與吳淑珍有期徒刑11年、8年確定，陳水扁自此在法律上始被定罪；但其被起訴的罪名，至2012年1月為止，亦有無罪確定者，有些案件則仍在法院審理中。然而，就政治責任而言，當2008年8月陳水扁坦承其妻曾將競選剩餘經費轉存海外帳戶，如同國民黨要人般將資金移至海外，業已重挫其政治信譽，再也沒資格領導臺灣的政治改革運動。參見王泰升，法律事件選粹 14. 總統「貪瀆」案，月旦法學雜誌，200期，頁363-365（2012年）。

126 關於國民黨集團式的藉執政之便奪取國家資產，例如參見王泰升，中國國民黨的接收「日產」為「黨產」，收於：台灣法的斷裂與連續，頁315-326（2002年）。國民黨的黨產不但是其在臺灣執政55年來累積的「貪瀆」所得，且構成對於現代民主政治下政黨應以其政見公平競爭的最大傷害，何「清廉」之有？執政的民進黨的個人或整個黨，若狃於國民黨向來的政治文化，竟向財團等收取涉及國家職權之行使的「贈金」，以作為支應選舉等支出的「黨產」，則與原本就不具道德光環的國民黨沒什麼兩樣，批判國民黨腐敗的選民又何必支持民進黨呢？因此，民進黨人若有任何貪瀆的行為，都將使國民黨的集團式貪瀆得以「阻卻違法」而成為最大受益者，因此不難理解擁護國民

然而，不能讓人滿意的民進黨政府應該被換成一個什麼樣的政府呢？是從制度面再改革，包括提出解決行政立法僵局的設計，以在西方憲政主義的權力分立架構下，讓國政運作更受公民監督的政府呢？還是讓另一批被傳播媒體形塑為具有「溫良恭儉讓」特質的「聖君賢相」來組成政府呢？事實上，臺灣社會中迄今仍有許多人不習慣西方式民主政治那種面對分裂社會、互讓以獲共識的「衝突——妥協」作法，而較執著於傳統中國儒家那種由有德的上位者確立「和諧」秩序的期待¹²⁷，故反倒懷念起「蔣經國式」展現出「風雨中寧靜」的威權專制統治。當2008年競選總統的國民黨籍馬英九團隊打出「完全執政、完全負責」的口號時，其所訴求的正是如同威權時代被神化的蔣經國那樣，經由一人一黨統合所有國家機關、中央與地方一體的方式來治國，而不再強調西方憲政主義的分權制衡理念。其實，若「完全執政」意味著完全掌控著國家權力，這樣的權力將使得執政者「完全不必負責任」，因為人民已失去對其追究責任的能力了。

2008年馬英九以高票當選總統，顯示其所揭示「蔣經國式」的統治模式得到臺灣社會相當廣泛的支持。何以在一個各種「自由民主」言說甚囂塵上的社會竟至如此？那些主張「自由民主」的人真的認同西方立憲主義所預設的不信任當權者／國家的根本前提嗎？回顧西方立憲主義進入臺灣社會的歷程，姑且不論一直反對此思想及制度者，就算是可支持立憲主義制度的臺灣民眾，於1920年代經常夾雜著反日本人「少數統治」的臺灣人意識，或屬於種族文化上的漢族意識；於1980年代及1990年代則分別經常夾雜著反外省人優越感及反外省人「少數統治」的本省人意識，以及反本省人（特別是當中福佬人）多數優勢的外省人意識。若是在「別有用心」的情

黨的傳播媒體與代表國民黨參選總統的馬英九，總是極力攻擊民進黨「貪腐」，而不管相關行為在法律上是否已被定罪。

127 關於擬以「聖君賢相」避免「分裂」的傳統中國觀念，亦參見王泰升（註15），頁40。

形下，使用這套來自西方的自由民主憲政制度，當然會「見異思遷」。此所以當2000年臺灣因歷史的巧合而實現自由民主憲政時，當務之急就是推動包括「轉型正義」在內的汰舊換新工程，以深化自由民主憲政理念；執政8年的民進黨逢此關鍵時刻卻未能充分地進行「汰舊」的工作¹²⁸，其失去執政地位事小，延誤臺灣的自由民主進程才是遺憾之所在。

從而，以標榜開明專制的「蔣經國」之姿重新獲得國家統治權力的國民黨，與從小就在自由民主憲政生活中長大的「野草莓」世代有所衝突，也就不令人意外了。臺灣自1990年代以後逐漸成長的一代，不像其上一代有許多人分別是出於對國民黨外來統治菁英、或對「奪權者」民進黨政治人物的厭惡始對抗政府，而是大多已傾向於認為人民當然可以監督政府，國家當然應該尊重人民的基本自由權利。也因此遂有青年族群們針對因中國特使來臺所引發的圓山事件，發起要求政府不得侵害人民集會遊行的自由的野草莓運動。然而，積累數十年的威權專制經驗、又剛在選舉中獲得選民支持的國民黨馬英九政府，已將與其在國族認同上有共識的中國政府建立合作關係列為施政之最優先¹²⁹，故以專制的心態，不惜運用國家警察暴力，阻止有異議的人民像他們在野時那樣上街頭表達意見。在民進黨等在野力量正處低迷之際，馬英九政府怎麼聽得進野草莓運

128 雖然民進黨執政時期積極開放政府檔案，以使學術界能據以批判過去國家對於人權的侵害等，但如前所述，其閃避了臺灣因承襲舊中國憲法而在法理上尚非獨立國家等憲政議題的揭示與討論，使得臺灣民眾沒太多機會知悉此問題在現實上的複雜性及其衍生的困難，並理解到若為了擁有自由民主憲政的生活方式，則在國家發展方向上應朝著成為法理上國家前進。執政者若只在既有架構中吸取選票，將失去根本上改變選票結構的機會。

129 國民黨馬英九政府之推動臺灣與中國的交往，並非純然從臺灣共同體的政治或經濟上利益著眼，而是帶有將臺灣納入與中國同一個政治經濟文化圈的意圖。此從馬英九等人所抱持的中國國族主義來看，屬於「大是大非」的善舉。也因此，並非謂臺灣國族認同者就不願意或不需要與中國開展合作關係，但就如臺灣國族主義的意涵所示，臺灣人民這個群體所建立的國家（目前國名叫「中華民國」），應該在與中國的交往中獲得對等的尊重，而不應變成一個地區，否則臺灣共同體的利益如何獲得確保？

動為民主自由所做的呼喚，也難怪其就以刻意忽視該運動的方式，靜待運動集結的漸次萎縮而消逝。

然而，臺灣終究在之前已有過自由民主憲政的實踐，為了在表面上向社會大眾有所交代，馬英九政府在圓山事件的喧騰告一段落後，即興致勃勃地自行簽署聯合國1966年的《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》兩項公約¹³⁰，並促使立法院三讀通過《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》¹³¹。不過馬英九政府仍一副「人民奈國家何」的模樣，實際上並不理會野草莓運動對於侵害人民自由權利的《集會遊行法》的修正訴求，也無視於論者對其「左手簽約、右手違約」的指摘¹³²。

上述的歷史發展，應足以讓臺灣民眾瞭解到：不管執政者是不是族群意義上的「自己人」，都是西方憲政主義所稱的國家／政府，均可能侵害人民基本人權，而皆應節制其權力。如果更多的臺灣人民能夠本於這樣的認知¹³³，而確立其抗拒國權的意識，則自由民主憲政理念即可深入人心。唯有靠人民在憲政實踐過程中的自覺與自決，並容忍民主程序可能出現的差錯¹³⁴，而不是倚賴本質上與

130 參見李明賢，駐台使節見證馬簽國際人權公約，聯合報，2009年5月15日A4版。

131 參見楊正海，兩公約三讀通過，聯合晚報，2009年4月1日A9版。在《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》第2條即規定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」

132 參見謝文華，東亞人權團體：政院版集遊法 抵觸兩人權公約，自由時報，2009年5月14日A5版。

133 筆者在上一句所提示的「應」節制國家／政府的權力，係屬應然層面的概念；在此套用「如果……」句法，以假設語句申論，乃意指實然又是如何，仍有疑問。

134 人民透過多數決所做的集體選擇，並不一定能確保該決定之為最適當，按依民主程序所為政策決定可能過於追求短期利益，民選首長也可能後來被認定為無能、有礙國家的發展；但只要民主制度仍在、人民知的權利能被確保，人民就有可能從錯誤的選擇中得到教訓，而趨向於做較好的選擇。因此，對多數決的結果不滿意的人，更要珍惜民主體制，並積極捍衛其發聲的權利，而不宜對民主失望。

民主不相容的「訓政」¹³⁵，才能在東亞社會建立一個自由民主憲政國家。不過，當一個得以操控除了法官以外的所有國家機構（包括檢察體系）¹³⁶、且在兩蔣時代掌政而於人權保障上有不良紀錄的執政團隊，於2012年竟還能再次贏得總統大選，則過半的臺灣人民究竟具有什麼樣內涵的憲政意識，確實值得再省思¹³⁷。

四、認同自由民主憲政的國家認同

因西方憲政主義在臺灣社會的昂揚而顯現的國族認同上分裂，同樣需要透過對自由民主憲政意涵的再省思來面對與解決。依西方自由主義的精神，國家／政府不能禁止人民提出任何特定的主張，故對同一件事，社會上經常存有相異的意見，且由各自追求其利益的個人或團體各吹各的調。按每個人都可能因其成長環境、教育或社會化過程、職業歸屬等等，而有文化觀念上或財產利益上的差異性存在，是以這種因多元而「分裂」的現象毋寧是自然的，有待循制度確立一個各方可接受的最大公約數。故自由主義強調的是「我反對你／妳的意見，但我誓死維護你／妳有表達這種意見的權利」。臺灣的「國族認同」問題，更由來於戰後臺灣社會包含了具有不同歷史經驗的本省、外省族群，且除了威權政府曾長期地推銷其所偏好而鎮壓其所厭惡者之外，於今可能還涉及每個個人現實的經濟或政治上利益的考量。當國家不再強制所有人民接受單一版本

135 關於民國時代中國施行「訓政」反而形成邁向自由民主憲政的阻力，參見王泰升（註69），頁69-228。

136 以2011年12月時為準，馬英九業已本於總統職權，提名行政院院長、考試委員及考試院正副院長、監察委員及監察院正副院長、司法院正副院長，以及有權指揮檢察體系的檢察總長，再以擁有龐大黨產的國民黨的主席身分，指揮在立法院佔有絕對多數席位的國民黨籍立法委員黨團，通過前揭各項人事提名。因此這些國家部門的權力運作，已被置於以馬英九為首的執政團隊掌控下。

137 於2012年1月14日，普遍被認為執政無能的馬英九總統，仍能獲得51.60%選票而連任成功，表示「做不好就應下台換人做」的民主政治基本理念，還不是臺灣社會普遍認為最重要的信念，可能仍有不少人認為「政治安定」最優先，並且將國民黨與「安定」做連結。

時，各式各樣的意見即自然地浮現出來。

雖然在多元開放的社會裡，人們可以擁有不同的國族認同，但是無論如何，一個國家的法律與政治制度必須基於一定的國族認同，來劃定國民及其領土的範圍。這種必須擇一的特性，不同於國家之可對宗教信仰採中立態度。因此，若臺灣人民真的接受民主的價值，而不是僅僅以之為政治鬥爭的口號，就應該依民主程序，包括開放而公平的傳播媒體與國家文化教育機構，以決定這項必須「歸於一」的國族認同。按民主程序並不是只有最後的投票決定，而應在投票前經充分的意見表達乃至相互辯論，故傳播媒體及國家的文教機構，應提供爭議雙方同等的闡述己見的機會，尤其是國民教育不應繼續獨尊中國國族認同。換言之，作為選項的是，國民黨、親民黨、新黨等所支持的「中國國族認同的中華民國」，以及民進黨、台聯等所支持的「臺灣國族認同的中華民國」，而「中華民國」則指稱由臺灣共同體內居住於臺澎金馬的人民所組成的國家。不過，從西方憲政主義多數決制度的精神而言，民主選舉的結果應具有將來的可變動性，亦即將來有改變為另一選項的可能，因此不容以多數決終結掉自由民主憲政體制。

由於臺灣國族主義只指出這個群體應建立一個國家，筆者在此則擬進一步釐清這應是一個具有什麼樣內涵的國家。奠基於西方憲政主義的臺灣國族主義所稱的「國家認同」，係以臺灣是一個具有如上所述包容不同國族認同的憲政秩序的國家為前提，再由人們認同這是自己的國家。按相對於國族認同之指涉應該以哪一些人組成一個國家，國家認同乃是強調應該以哪一種憲政生活方式來經營國家；具體而言，即是以對自由民主憲政秩序的認同，作為對臺灣這個國家的認同的實質內涵。既然歷史上加拿大、澳大利亞、紐西蘭等皆能從實施自由民主憲政的自治殖民地／政治實體，發展成為主權獨立的國族國家，在臺灣為什麼不可能呢？這曾經是1920年代某些臺灣知識菁英，在理解殖民主義及憲政主義之後，擬以設置臺灣議會作為起步所欲追尋的目標。臺灣於二次大戰後未能趁著可脫離

殖民母國的機緣而獨立建國，但1949年之後成為事實上主權獨立國家的局勢，卻已然存在。既然澳大利亞能在形式上由英國女王為其國家元首，而實際上為一主權獨立國家，則臺灣在形式上使用來自民國時代中國的中華民國體制，而實際上就是主權獨立國家，又有什麼不可以呢？只要自由民主憲政秩序被遵從，整個國家要怎麼改變，就讓這個憲政體內的人民來做決定吧，像澳大利亞即曾於1999年就廢除英國女王為國家元首以改制為共和國進行過公民投票¹³⁸。

回顧臺灣歷史，一路筆路藍縷地朝著接納西方憲政主義的方向前進，終於在1990年代透過各種民主選舉而實現了自由民主憲政，雖然憲政文化內涵上仍有待再深耕。於今，臺灣人民應已有足夠的經驗來思考：以對自由民主憲政的認同，作為自己的「國家認同」。至於國名、國旗、國歌，都是次要的問題，因為其均可依民主程序來處理。對於筆者而言，之所以堅持臺灣國族主義，之所以捍衛臺灣具有作為主權獨立國家的地位，就是為了保障在臺灣既有的自由民主憲政的生活方式。簡單的說即是：「我是台灣人，因為我要做一位自由人。」¹³⁹

伍、結論：歷史思維下的未來展望

隨著2000年與2008年兩次政黨輪替的實踐，西方憲政主義彷彿已是理所當然地存在於臺灣社會。對此，本文嘗試透過歷史的回顧，描述臺灣社會與西方憲政主義的歷次交會，從一開始的《大日

¹³⁸ 在澳大利亞1999年這次公投，由於反對改制的執政黨故意提出由國會間接選出總統的共和制，以致眾多主張總統直接民選者只好投反對票，故最終反對票達55%，公投案未通過，英國女王則表示對該國的任何公投結果都尊重。參見王泰升（註118），頁189。

¹³⁹ 以上見解可闡釋自由民主憲政主義與國族主義的悖離與相容，參見王泰升（註74），頁151。

本帝國憲法》、到後來的《中華民國憲法》，以及從日治時期以來，堪稱「屢敗屢戰」之由各個時代知識菁英及追隨群眾所推動的自由民主運動，當可體會今日自由民主憲政之得來不易。誠然憲政文化必有其傳承的面向，面對今日臺灣社會實踐自由民主憲政的可能困境，法律史研究提供這般具有歷史思維的回顧，實有據以確立當代應然方向的期待。畢竟憲政文化是需要創新的，對於過去的理解，無疑是為了培養對於不同歷史經驗或立場的包容心；但是理解並不等於贊同，我們仍須依今日的價值選擇，批判過往統治者對於人民基本權利的壓制，以期過去那些不公義的歷史不會再現於未來。

容於此再次澄清的是，雖然西方憲政主義思想曾在歷史的進程中，被賦予「文明」或「先進」的意義，但這並不表示其本質即為如此。按西方憲政主義作為一種文化與生活方式的展現，並無所謂先進或落後於他種文化及生活方式，而僅是人類共同的文化結晶之一。因此，儘管臺灣社會一開始是在帶有文化上成見的歷史環境中，展開與西方憲政主義思想的互動；在百餘年以後的今日，臺灣人民對於自由民主憲政思想或制度的選擇，已比較是基於對其生活方式內涵，亦即對於社會階層具有流動性、政治意見具有可變性等等的認同，而願意以之替換固有的傳統憲政觀念。對傳統文化觀的延續，不是基於義務，而是出於必要¹⁴⁰；同樣的，對西方的事務與價值觀既不必一味排斥，也不宜貿然引進，總應在考量利弊得失之後再做選擇¹⁴¹。

或有論者質疑，源自西方、強調以共同政治利益而結合的近代西方主權國家／國族國家的觀念，是否真有辦法取代已深植華人心田的傳統觀念¹⁴²？其實文化觀念是具有流動性的，例如華人傳統上

140 參見楊日然，法理學，頁242（2005年）。

141 參見王泰升，變遷中的台灣人民法律觀，收於：台灣法的斷裂與連續，頁212-213（2002年）。

142 陳顧遠以歷代史家所刻畫的大一統史觀為依據，認為「以『統一』言：……此種歷久的歷史勢力，鑄入（華人）人心」，從而指摘「外人（所稱之）『兩

的男尊女卑觀念在臺灣不也逐漸式微了嗎？來自於他種文化觀念的刺激，將促使社會大眾開始思考「舊觀念應該被取代」，若再加上政經與社會力量的推動，人們的法律文化觀確實具有改變的可能性。況且西方憲政主義縱然產自西方社會，卻不過是一種政治理想的呈現，就如同傳統東亞社會不斷地試圖成就儒家所構思的「聖君賢相」理想一般¹⁴³，歐美各國縱令共同懷抱自由民主的理念，仍然不斷地依其自身的歷史社會文化根基，展現出內容不完全相同的憲政體制¹⁴⁴。就此而論，臺灣社會也將在自身歷史文化的土壤上，發展出具有在地脈絡的自由民主憲政秩序，其表現方式不必然與歐美國家一模一樣¹⁴⁵。

西方憲政主義之在臺灣社會開花結果，有一段曲折的過程。臺灣社會於19世紀末日本殖民統治者到來之時，即與西方憲政主義發生幾乎可謂「無感」的初次接觸，蓋憲法的論述權力係被握於仍需西方專家協助的日本明治政府領導階層，姑且不論當時日本明治憲法本身即被評為僅具立憲主義外觀，臺灣人對於國家法能有多少立憲主義成分既不知也無從改變。相對於此，1920年代一些臺灣人知識菁英所推動的議會請願運動，就展現其對西方憲政主義的理解及加以善用的企圖，其雖終告失敗，但亦促使臺灣人得以1935年後初次體驗民主選舉；不過，當時的高山族原住民族，仍幾乎與西方憲政主義思想或制度絕緣。

個中國』為「與天下大勢，國際正義不合，且按諸我國歷史，亦南轅北轍」的「謬論」（括弧內容為筆者所補充）。參見陳顧遠，中國文化與中國法系，頁178-179（1969年）。

143 在東亞受儒家教義影響之當今各為主權國家的中國、韓國、日本，在其各自的歷史上都曾本於儒家所揭示的價值，而建構適合自身政經社文條件的統治制度，三者並不全然相同。於今作為新興國家的臺灣，同屬儒家文化圈，故如前所述仍受「聖君賢相」觀的影響。

144 參見王泰升（註74），頁101-106。

145 例如澳大利亞在英國殖民地體制上建立起來的自由民主憲政形式，與美國以獨立戰爭脫離殖民主英國而建立的自由民主憲政形式恐有不同，但兩者均可謂存在著自由民主憲政秩序。

戰後來臺統治的國民黨外省政治菁英，帶來了具有西方憲政主義憲法條文但以動員戡亂及戒嚴凍結其效力的中華民國憲政體制，而實質上延續其在中國訓政時期悖離立憲主義的法律生活方式。由於具日治經驗的本省人族群中已無力足以對抗國民黨／國家權威的政治菁英，故僅有少數來自中國的自由主義者，例如雷震，在政府「毀憲」程度令其無法忍受的情況下與之對抗，但其未能鼓動起遭受政府壓制之本省人群眾的支持，因此又告失敗。然而，於1970年代和1980年代，某些接受戰後西方憲政主義思潮的新生代法學者，以及以本省人族群為主之「黨外」及民進黨政治菁英，重新集結以對抗國民黨政府，而國民黨除繼續培育外省政治菁英，更吸納某些本省人政治菁英以應民主選舉之需。作為西方立憲主義社會基盤之一的存在兩股以上政治勢力，已悄然出現其雛形。1988年蔣經國逝世而由李登輝在1990年代將臺灣社會導向自由民主化，並於2000年經由首次政黨輪替實現了自由民主憲政，都是在此一延長線上的作為。

在此擬從描述、而非評價的立場，以與西方自由民主憲政主義理念（而非僅是表現方式）的吻合度作為給分標準，針對與臺灣相關的憲法典、政權或人物來打分數。施行於臺灣的第一部具現代意義憲法的《大日本帝國憲法》，以其形式意義的君主立憲制居多，僅能得到勉強及格的60分。在日本統治下的臺灣殖民地憲政體制，剝奪了一部分明治憲法所賦予的基本人權，故只剩不及格的50分。然而1920年代起某些臺灣人知識菁英，欲超越明治憲法的框架與侷限，爭取自治殖民地的議會民主，其憲政思想已提升至70分的程度。戰後來臺統治的國民黨政權，處於連立憲政治的形式都沒有的訓政時期，以黨治國，只能得到比殖民地臺灣還差的40分，其如何能夠讓具有日治時期經驗的人們信服呢？不過，就在臺灣被充作中國一省的戰後初期，中國出現了一部以憲法保障基本人權，且有司法違憲審查制度的《中華民國憲法》，以法規範內容而言確可獲得80分。但實難以期待只有40分的政權來實施高達80分的憲法條文，

因此在生效後不到一年即被修改為幾乎等於否定憲法上基本人權之規定的「動員戡亂戒嚴體制」，僅存權力分立之形式，故已降到符合其政權實質內涵的40分的水準。1949年年底在臺灣所形成之猶以「中華民國」為國號的事實上國家，其憲政體制就從這樣的40分開始。經臺灣人民前仆後繼的爭取，先以解嚴及終止動員戡亂回歸到憲法原有的80分，再經1990年代包括增修憲法條文在內的自由民主化，終於在2000年終結國民黨在臺灣55年的一黨專制，開啟政黨輪替時代，而達到了90分的自由民主憲政生活，但還有那僅剩的10分的努力空間。

換言之，經此一過程所結出的自由民主憲政的果實，還未百分之百成熟。過去只靠不斷的選舉來堆砌自由民主憲政的外觀，卻一直未培育出在對抗之後必要的相互協商、形成共識的憲政文化，持續對抗的結果甚至讓國家付出發展停滯的代價。並沒有趁在野期間改變過去威權文化體質的國民黨，於2008年重新執政，馬上與在自由民主社會中成長的野草莓世代發生衝突，其雖成功地壓制該運動，但諸如架空立法權而與中國簽訂多項協議等寡頭獨斷的行為，令人感受到一黨專制的復活。尤其是馬英九政府本於其所認知的「中國國族認同的中華民國」而採親中政策，全然忽視因1990年代自由民主氛圍而興起的臺灣國族認同者的反應，或許其根本不習慣在價值多元的民主社會裡處理國政吧！

在此時刻，臺灣人民應補修過去因急於「使用」民主選舉，而來不及思考的西方憲政主義之法政理念的基本精神。瞭解到國家應以自由民主憲政的生活方式，確保每一位國民都能自由的發揮其才能、追求並實現其個人幸福，來作為對國家產生認同的核心，從而凝聚出可以超越包括族群意識、國族認同等種種差異性的國家意識。讓臺灣的「國家認同」，就等於是對自由民主憲政生活方式的認同，進而得以如歷史所揭示的加拿大、澳大利亞、紐西蘭等例證一般，透過自由民主憲政的實施，發展成為主權獨立的國族國家。

參考文獻

1. 中文部分

- E. Patricia Tsurumi著，林正芳譯（1999），日治時期台灣教育史，宜蘭：仰山文教基金會。[E. Patricia Tsurumi. 1977. *Japanese Colonial Education in Taiwan, 1895 – 1945*. Cambridge, MA: Harvard University Press.]
- 王泰升（2002），中國國民黨的接收「日產」為「黨產」，收於：台灣法的斷裂與連續，臺北：元照，頁315-326。
- （2002），中華民國法體制的台灣化，收於：台灣法的斷裂與連續，臺北：元照，頁147-192。
- （2002），變遷中的台灣人民法律觀，收於：台灣法的斷裂與連續，臺北：元照，頁193-213。
- （2004），自由民主憲政在臺灣的實現——一個歷史的巧合，臺灣史研究，11卷1期，頁167-224。
- （2005），台大法學教育與台灣社會（1928-2000），收於：台灣法的世紀變革，臺北：元照，頁103-269。
- （2005），台灣憲法的故事——從「舊日本」與「舊中國」蛻變而成「新台灣」，收於：台灣法的世紀變革，臺北：元照，頁271-321。
- （2006），日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」，收於：台灣法律史的建立，2版，臺北：自版，頁99-158。
- （2006），台灣日治時期憲法史初探，收於：台灣法律史的建立，2版，臺北：自版，頁183-255。
- （2007），台灣近代憲政文化的形成——以文本分析為中心，臺大法學論叢，36卷3期，頁1-49。

- （2009），台灣法律史概論，3版，臺北：元照。
- （2009），國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁69-228。
- （2010），具有歷史思維的法學——結合台灣法律社會史與法律論證，臺北：自版。
- （2011），日治時期高山族原住民族的現代法治初體驗——以關於惡行的制裁為中心，臺大法學論叢，40卷1期，頁1-98。
- （2011），四個世代形塑而成的戰後台灣法學，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1367-1428。
- （2012），法律事件選粹 14. 總統「貪瀆」案，月旦法學雜誌，200期，頁363-365。
- 王泰升、曾文亮（2011），台灣法學會四十年史，臺北：社團法人台灣法學會。
- 王泰升、曾文亮訪問（2011），台灣法律人的故事，臺北：社團法人台灣法學會。
- 王泰升、薛化元、黃世杰編著（2006），追尋臺灣法律的足跡——事件百選與法律史研究，臺北：五南。
- 台北律師公會編（2005），律師雜誌，309期。
- 田弘茂著，李晴暉、丁連財譯（1989），大轉型——中華民國的政治和社會變遷，臺北：時報文化。[Hung-Mao Tien. 1989. *The Great Transition: Political and Social Change in The Republic of China*. Stanford, CA: Hoover Institution Press.]
- 朱雲漢（2001），國民黨與台灣的民主轉型，二十一世紀雙月刊，65期，頁4-13。
- 行政院研究發展考核委員會編（2003），美麗島事件檔案導引，臺北：行政院研究發展考核委員會。
- 坂野潤治著，鍾淑敏譯（2008），近代日本政治史，臺北：五南。
- [坂野潤治（2006），近代日本政治史，東京都：岩波書店]

吳乃德（1993），省籍意識、政治支持和國家認同——臺灣族群政治理論的初探，收於：張茂桂等，族群關係與國家認同，頁27-51。

吳文星（2008），日治時期臺灣的社會領導階層，臺北：五南。

吳文星、廣瀨順皓、黃紹恆、鍾淑敏編（2006），臺灣總督田健治郎日記（中），臺北：中央研究院臺灣史研究所。

——（2009），臺灣總督田健治郎日記（下），臺北：中央研究院臺灣史研究所。

吳庚（2005），感念 林師紀東，收於林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集，頁114-117。

吳密察、吳瑞雲編譯（1992），臺灣民報社論，臺北：稻鄉。

李建良（2007），人民與國家「身分連結」的法制詮要與法理探索——兼論台灣人國籍的起承斷續問題，臺大法學論叢，36卷4期，頁1-60。

——（2008），為「笨總統」上一堂憲法實例課——1106圓山事件案——，台灣法學雜誌，117期，頁1-5。

李筱峯（1991），台灣民主運動40年，臺北：自立晚報。

李鴻禧（1997），憲法與憲政，臺北：自版。

周婉窈（1989），日據時代的臺灣議會設置請願運動，臺北：自立報系。

——（2011），臺灣議會設置請願運動再探討，台灣史料研究，37號，頁2-31。

林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞編著（2009），憲法——權力分立，2版，臺北：新學林。

林紀東（1992），中華民國憲法釋論，55版，臺北：自版。

林慈舟（即林呈祿）（1920），六三問題之運命，臺灣青年，1卷5號，漢文之部，頁16-29。

林獻堂先生紀念集編纂委員會編（1974），林獻堂先生紀念集卷

二——遺著，臺北縣：文海。

徐聖凱（2009），日治時期台北高等學校之研究，國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文。

翁岳生（2005），是經師，更是人師，收於：林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集，頁100。

記者（即林呈祿）（1921），就臺灣議會設置之請願而言，臺灣青年，2卷2號，漢文之部，頁19-25。

國立臺灣大學法律學院編輯（2009），從法學觀點論1106圓山事件，國立臺灣大學法律學院院訊，6期，頁2-27。

張麗俊著，許雪姬、洪秋芬解讀（2000），水竹居主人日記（一），臺北：中央研究院近代史研究所。

許宗力（2002），基本權利——第一講 基本權利的起源與發展，月旦法學教室，試刊號，頁84-90。

許雪姬（1998），林獻堂著《環球遊記》研究，臺灣文獻，49卷2期，頁1-33。

許雪姬等著（2004），臺灣歷史辭典，臺北：行政院文化建設委員會。

陳世宏等編（2002），雷震案史料彙編——國防部檔案選輯，臺北：國史館。

陳鈺雄（1996），日治時期的台灣法曹——以國家為中心之歷史考察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

陳顧遠（1969），中國文化與中國法系，臺北：三民。

賀德芬（2005），巨人的身影，遠去……，收於：林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集，頁145-149。

黃富三編（2001），臺灣地區戒嚴時期政治案件——五〇～七〇年代文獻專輯——美麗島事件，南投：臺灣省文獻委員會。

黃榮堅（2008），問題不在暴力，問題在正當性，台灣法學雜誌，

117期，頁6-9。

楊日然（2005），法理學，臺北：三民。

葉俊榮（1999），從國家發展與憲法變遷論大法官的釋憲機能——一九四九至一九九八，臺大法學論叢，28卷2期，頁1-63。

劉振強（2005），懷念林紀東先生，收於：林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集，頁42-43。

蔡一舟（1923），關於請願臺灣議會敬告島內同胞，臺灣，4年1號，漢文之部，頁3-5。

鄭麗玲（2001），帝國大學在殖民地的建立與發展——以臺北帝國大學為中心，國立臺灣師範大學歷史研究所博士論文。

薛化元（1996），《自由中國》與民主憲政——1950年代臺灣思想史的一個考察，臺北：稻香。

薛化元、周志宏（1996），百年來台灣教育法制史的考察——以國家權力與教育內部事項為中心，收於：台灣法學會編，台灣法制一百年論文集，頁460-495。

謝清志、彭琳淞（2008），謝清志的生命振動，臺北：玉山社。

韓忠謨（1977），法學緒論，6版，臺北：自版。

2. 外文部分

(1) 日文

內閣記錄課編（1915），臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律其ノ沿革並現行律令，東京：內閣記錄課。

安井勝次（1907），生蕃人の國法上の地位に就て，臺灣慣習記事，7卷1號，頁1-27。

伊藤博文編（1936），臺灣資料，東京：秘書類纂刊行會。

園部敏（1943），行政法概論——特に臺灣行政法規を顧慮して——，改訂版，臺北：臺灣出版文化。

- 家永三郎（1967），日本近代憲法思想史研究，東京：岩波書店。
- 外務省条約局編（1990），日本統治下五十年の台湾（「外地法制誌」第三部の三），復刻版，東京：文生書院。
- 佐々木惣一（1932），日本憲法要論，3版，東京：金刺芳流堂。
- 三好一八（1919），獨立せる臺灣の司法，臺法月報，13卷8號，頁61-69。
- 秀湖生（1923），臺灣議會と無產階級解放，臺灣，4年7號，和文之部，頁43-48。
- 松田吉郎（2004），台湾原住民と日本語教育，京都：晃洋書局。
- 大石眞（2005），日本憲法史，2版，東京：有斐閣。
- 編輯員（1922），臺灣議會設置請願に就て，臺灣，3年1號，和文之部，頁29-41。
- （1923），第三回臺灣議會設置請願，臺灣，4年3號，和文之部，頁2-19。
- 北村嘉恵（2008），日本植民地下の台湾先住民教育史，札幌：北海道大学出版会。
- 有賀長雄（1901），國法學（上冊），東京：東京專門學校出版部。
- 臺灣總督府官房審議室編（1940），律令制度ノ沿革，臺北：臺灣總督府官房審議室。
- 臺灣總督府警務局編（1942），臺灣總督府警察沿革誌第二編：領臺以後の治安狀況（下卷），臺北：臺灣總督府警務局。
- （1995），臺灣總督府警察沿革誌第二編：領臺以後の治安狀況（上卷），復刻版，臺北：南天書局。

(2) 西文

- Chen, Edward I-te. 1984. The Attempt to Integrate the Empire: Legal Perspective. Pp. 240-274 in *The Japanese Colonial Empire, 1895-1945*, edited by Ramon H. Myers and Mark R. Peattie. Princeton, NJ: Princeton University Press.